

Marco Legal de la Información
Clase 1
Elementos Básicos de la ciencia jurídica

El Derecho

1.1 Concepto: El concepto de derecho genera grandes controversias, según la postura iusfilosófica que se adopte. Veamos algunos ejemplos:

El derecho es la realidad compuesta por conductas humanas en relación de alteridad social¹

...conjunto de normas de conducta humana obligatorias y conformes con la justicia²

...Un orden coactivo, como un sistema de normas que prescriben o permiten actos coactivos bajo la forma de sanciones socialmente organizadas³

Cabe preguntarse, sin embargo, si estas definiciones constituyen un elemento útil para comprender un fenómeno jurídico determinado (¿cual es el derecho argentino?) o si, en cambio, constituyen un intento de aprehensión de las supuestas características comunes a todos los ordenamientos, mas allá de las particularidades de cada uno (¿Que es derecho?).

Las infinitas y muchas veces bizantinas discusiones respecto a la realidad del derecho, esconden en realidad la concepción muchas veces no expresadas respecto a que la validez del derecho deriva de una idea anterior de carácter imanente, a la que el primero debe necesariamente referir. En función de ello, la definición abstracta de derecho cobra vital importancia, atento que constituye el standard respecto del cual un conjunto organizado de normas se compara a los efectos de otorgarle o no la categoría de derecho.

En otras palabras si, por ejemplo, adoptamos la definición de Borda, podemos llegar a concluir que toda norma contraria a los derechos humanos fundamentales no constituye derecho, por ser eminentemente injusta. Dicha concepción, si bien puede ser loable desde el punto de vista moral, desconoce toda regulación sobre el comercio de esclavos, institución si se quiere aberrante, la que sin

¹ Bidart Campos, "Tratado elemental de derecho constitucional", Tomo 1, pag. 29, Ediar, Bs As, 1989

² Borda, Guillermo, "Tratado de derecho Civil - Parte general" Tomo I, pag. 12, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1987

³ Kelsen, Hans, "Teoría Pura del derecho", Pag. 71, Eudeba, Buenos Aires, 1986.

embargo, se mantuvo con variaciones por el término de mas de dos mil años, lapso visiblemente superior a la declaración derechos del hombre.

En realidad, las definiciones de derecho expuestas al comienzo del presente párrafo, constituyen los que algunos autores denominan “*definición persuasiva*”, al cual necesariamente incluye una toma de posición del estudioso frente al objeto a definir; posición que se traslada e influye en su interlocutor a través de una definición que se entiende objetiva⁴. En verdad, la mera descripción del objeto no debería impedir su calificación autónoma desde el punto de vista valorativo: Vg. El hecho que se admita el contrato de compraventa de esclavos como derecho no implica en modo alguno el apoyo a la institución.

Frente a esta realidad, la definición de un ordenamiento jurídico, se torna mucho más simple, si nos restringimos a un ordenamiento determinado, evitando los intentos generalizadores. Atento a ello, podemos definir al **ordenamiento jurídico**, como **el conjunto organizado de normas emanadas de un poder estatal competente, las cuales son percibidas por la población como obligatorias.**

Analicemos la definición por partes:

Conjunto organizado de normas: Todo ordenamiento jurídico implica necesariamente una jerarquía entre las distintas normas que lo componen, de forma que sea posible definir en forma previsible cuál es la ley aplicable a un caso concreto.. Principios como la supremacía constitucional o la de la ley penal más benigna simplemente constituyen formas de definir en el caso de leyes en conflicto cuál de ellas será la prevalente. De esta manera, los sujetos de derecho pueden saber de antemano cuales serán las consecuencias legales de sus conductas y adecuar las mismas en función de ello.

Emanadas de un poder estatal competente: Toda norma necesariamente deriva su fundamento de la existencia de un estado que la crea y esta encargado de velar por su cumplimiento. Aún en los casos en que la norma parece emanar de los particulares, es el estado que reconoce dichas convenciones y les otorga o no efectos jurídicos. En nuestro ordenamiento, dicho principio se encuentra consagrado en el art. 1197 del Cod. Civil. al sostener que las convenciones nacidas de los contratos vinculan a las partes “...*como la ley misma*”.

⁴ Al respecto, ver Ross, Alf, “Sobre el derecho y la justicia”, pag. 57 y sig., Eudeba, 1997.

El problema de la competencia, hace referencia a cuales son los organismos con potestad para ejercer esta capacidad normativa. Debe tenerse en cuenta que una norma dictada por un organismo incompetente carece de efecto, y por ende no forma parte del ordenamiento. Sobre este problema volveremos en oportunidad de analizar las formas del estado y el gobierno.

Las cuales son percibidas por la población como obligatorias:

Cualquier norma jurídica debe, por necesidad, contemplar mecanismos que permitan corregir o castigar el apartamiento de las conductas que pregonan, so pena de transformarse en una mera recomendación. En función de ello, podemos decir que la coerción forma parte necesaria de cualquier ordenamiento jurídico. Hans Kelsen⁵ sostiene que lo nota definitoria de una norma jurídica la constituye la sanción, que es consecuencia de la conducta jurídicamente disvaliosa. La misma es definida *“como un acto coactivo que consiste en la privación, forzada si es necesario, de bienes tales como la vida, la libertad o cualquier otro valor, tenga o no contenido económico”*.

En realidad, la característica analizada guarda directa relación con el carácter estatal del ordenamiento. Entre ambas constituyen uno de los elementos esenciales de la moderna doctrina jurídica⁶: La prohibición de la justicia por mano propia o visto desde la perspectiva del estado, el monopolio de la fuerza por parte de este último. De esta forma, es el estado, quién, a los efectos de regular la conducta de los individuos, mantiene para sí la potestad de hacer cumplir las leyes por él dictadas. Desde esta óptica, el ordenamiento jurídico se presenta como un regulador de la fuerza, definiendo bajo que circunstancias y mediante que organismos, la misma es aplicada a los particulares sujetos a su esfera de soberanía.

1.2 Derecho Objetivo y Subjetivo:

1.2.1. Concepto: La palabra derecho, en realidad es usada en un doble sentido. En primer lugar, tal como analizamos en el apartado anterior, como el conjunto organizado de normas vigentes de un país. A este aspecto se lo conoce como derecho objetivo, positivo o vigente.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el derecho objetivo, tal como su nombre lo indica, mantiene un carácter general, sin especificar situaciones particulares. Por ejemplo, el art. 1113 del

⁵ Kelsen, Hans, Op. Cit., Pag. 70 y sigs.

⁶ Debe tenerse en cuenta que, en ordenamientos antiguos como el Romano, existían formas de cobro compulsivo ejecutadas por el acreedor sobre la persona del deudor.

Código Civil plantea la obligación de reparar los daños producidos por peligros derivado de las cosas, sin especificar si en el caso concreto, una persona en particular tiene o no derecho a reclamar daños y perjuicios a otra por un hecho determinado. Por tanto, existe otro aspecto de la palabra derecho que refiere a los efectos que sobre los particulares tiene el ordenamiento jurídico. A este aspecto, se lo conoce como derecho subjetivo y se lo puede definir *como la facultad legal de exigir a otra persona una determinada conducta*⁷.

Como se puede ver en realidad, ambos conceptos guardan una estrecha relación, de forma tal que el derecho subjetivo constituye a la vez la consecuencia y el aspecto dinámico del derecho objetivo: Mientras este constituye una enunciación estática de carácter general, el subjetivo es su aplicación a una situación determinada en el tiempo y en sus sujetos, permitiendo la efectiva aplicación de los presupuestos expresados en la letra fría de la ley.

Mucho se ha sostenido respecto a cuál es la naturaleza de los derechos subjetivos. Las teorías clásicas, sostienen que se trata de un reconocimiento de una voluntad por parte del derecho. Esta concepción es criticada principalmente por su carácter absoluto: Si el ejercicio de una voluntad reconocida por el derecho es válido, cualquier acto que esta voluntad realice, más allá de su carácter abusivo, constituye un acto lícito.

La primera limitación a este concepto, provino de la doctrina alemana. En el siglo XIX, uno de sus máximos exponentes, Von Ihering, sostuvo que constituía “...una *interés jurídicamente tutelado*”. A este respecto, el cambio, más allá de su diferencia semántica, permite sostener que el ejercicio de un derecho encuentra su límite en el interés que el legislador mantuvo al consagrarlo. Dicha concepción dio pie durante el siglo XX a la elaboración de la doctrina del ejercicio abusivo de un derecho o abuso de derecho como causal de responsabilidad patrimonial.

Desde un punto de vista lógico, existen voces que niegan la existencia de un derecho subjetivo. Kelsen sostiene que en realidad los sujetos no serían titulares de derechos sino simplemente de obligaciones impuestas en beneficio de un tercero. Ello obedece a que dentro de la concepción kelseniana la norma se circunscribe a marcar las obligaciones del sujeto, no a definir sus derechos. Por tanto, lo que para la doctrina tradicional es un derecho, para el autor austríaco es el cumplimiento de un deber por parte del obligado.

Más allá de la discusión filosófica, el instituto del derecho subjetivo cumple numerosas funciones dentro del ordenamiento. La principal es la idea de una titularidad de derecho, que constituye una

⁷

Borda, op cit, pag. 35 sig.

parte fundamental del derecho procesal, al definir quien puede reclamar la ejecución forzada de un derecho, concepto conocido como legitimación activa.

1.2.2. El derecho objetivo: Sus divisiones: Si bien el ordenamiento constituye un único sistema, a los efectos de su estudio, la ciencia jurídica lo ha dividido en diferentes ramas, cada una de las cuales mantiene una autonomía científica respecto de las demás.

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que estas divisiones son básicamente arbitrarias y en muchas ocasiones la solución de los problemas jurídicos involucran dos o más ramas al mismo tiempo

Los principales criterios clasificatorios son:

A.- Derecho de forma y fondo o sustancial: Esta clasificación divide las normas jurídicas en función de si las mismas definen derechos o relaciones jurídicas entre las partes o si por el contrario, constituyen reglas destinadas a conducir los procedimientos ante la autoridad competente en caso que estos derechos se encuentren en disputa. En el primer caso nos encontramos frente a una norma de fondo o sustancial y en el segundo, frente a una norma de procedimiento o de forma.

Esta diferenciación reviste particular importancia en nuestro país atento la facultad delegada de las provincias en la nación de legislar la legislación de fondo.

B.- Derecho Público y Derecho Privado: ha existido durante largo tiempo una discusión respecto a cuál es el concepto preciso del derecho público. En principio, se lo definió como aquel donde la relación entre las partes no es horizontal o entre dos iguales sino que existe un componente de subordinación del individuo respecto del estado. El problema de esta definición radica en el hecho que no toma en cuenta al derecho internacional público, cuyas relaciones se establecen entre estados soberanos, circunstancia que elimina todo tipo de subordinación.

En realidad, la sola presencia del estado en una relación jurídica no permite afirmar que estamos frente a una figura del derecho público, es necesario que el mismo se encuentre cumpliendo su función de poder público, entendiendo el mismo como aquellas actividades esenciales para el desenvolvimiento social (vg justicia, seguridad, educación), en contraposición con el accionar del estado como persona de derecho privado (en los casos en que el estado realice contratos civiles como alquileres o compraventa de insumos).

Entre las ramas del derecho público se encuentran:

El Derecho Constitucional: Podemos hablar del derecho constitucional en un doble criterio⁸: Con un criterio formal, es el estudio del texto constitucional. En un sentido material, el constitucionalismo constituye el análisis de la estructura del poder del estado, entendiendo el mismo como el mecanismo que limita y define la toma de decisiones del estado, ya sea que el mismo este contenido en texto constitucional o se encuentre fuera del mismo. De esta forma cuando hablamos de constitucionalismo en el sentido material no solo nos interesará el texto que consagra, verbigracia, la libertad de prensa, sino que, asimismo, es de vital importancia entender cual es la postura que al respecto han mantenido los tribunales.

El Derecho Penal: Establece y regula el poder punitivo del estado respecto a conductas previamente calificadas como delitos.

El Derecho Internacional Público: Rige las relaciones entre los estados como poder público.

El Derecho Administrativo: Regula el funcionamiento de la administración pública y las relaciones entre la misma y los particulares.

El derecho privado, en su concepción más clásica, carece de la nota de orden público que caracteriza a su contraparte. Las relaciones se establecen entre partes en pie de igualdad y los bienes jurídicos protegidos revisten un carácter más económico que social.

En la actualidad, los conceptos antedichos están puestos en tela de juicio, produciendo la introducción de elementos del derecho público en las relaciones económicas. Fenómenos como el constitucionalismo social, la economía de masas o los movimientos sociales de principios del siglo XX, llevaron a limitar el concepto de propiedad así como el axioma de la igualdad de las partes al contratar. Atento ello, el derecho interviene a los efectos de equilibrar la relación contratar de forma tal de evitar los abusos que la posición dominante de una parte pueda tener sobre la otra.

Entre las ramas del derecho privado, podemos mencionar:

El derecho civil: En realidad, el derecho civil es la más antigua de las ramas del derecho. En el derecho romano, el derecho civil (*ius civile*) se refería a todo el orden jurídico que se aplicaba a los ciudadanos, en contraposición al *ius gentium*, que denominaba al derecho que se aplicable al resto de los habitantes del imperio. Dicho derecho contaba con normas tanto de derecho público como

⁸ Bidart Campos, Op cit, pag. 35 y sig.

de derecho privado, circunstancia que lo diferencia de manera clara de su concepción moderna.

Son los glosadores medievales los que dan forma al derecho civil tal como lo conocemos, al recuperar la legislación romana y eliminar las regulaciones referentes al poder estatal, las cuales ya carecían de sentido, atento el hecho que el imperio había desaparecido casi mil años antes.

En razón de ello, el derecho civil constituye la rama más antigua y de la cual las distintas ramas se derivan. Precisamente por esta circunstancia histórica, el derecho civil es muchas veces conceptuado como un derecho por sustracción, un cúmulo amorfo de normas y principios que restan una vez separado las relaciones jurídicas regidas por las otras ramas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el derecho civil en su concepción actual mantiene un objeto de estudio que son las relaciones jurídicas que se establecen frente los sujetos de derecho en su condición de tales y con independencia de la actividad que desarrollen. Así por ejemplo, las relaciones familia, las relaciones de propiedad, los actos jurídicos y los mismo derechos derivados de la condición de persona jurídica (derechos personalísimos), constituyen objeto de estudio de esta rama del derecho.

El derecho comercial: Regla la estructura de la empresa, las relaciones de los comerciante y las consecuencias jurídicas de los actos de comercio que se realizan.

El derecho laboral: Norma las relaciones derivadas del contrato de trabajo, ya sea a nivel individual como en los casos de negociación colectiva. En realidad, la ubicación del derecho laboral dentro de la órbita del derecho privado obedece a cuestiones históricas derivadas del desprendimiento del derecho civil. Sin embargo una de sus notas definitorias esta dada por el denominado orden público laboral, es decir la limitación del poder de disposición de los particulares en la negociación de los términos del contrato. Esta característica, sumada a la intervención activa del estado en la negociación y control del contrato de trabajo, hace que esta rama del derecho presente elementos de ambas clasificaciones, lo que lo torna en un figura mixta.

Las fuentes del derecho:

1.- Concepto: La expresión fuentes del derecho es utilizada a los efectos de denominar conceptos diferentes. En un sentido filosófico, refiere a los antecedentes ideológicos tenidos en cuenta a los efectos de la redacción de la ley. Este es el sentido que se le da en el preámbulo de la constitución cuando invoca a dios “...*fuentes de toda razón y justicia*”.

En similar sentido pero desde el punto de vista histórico, las fuentes del derecho constituyen los antecedentes legales, sociales o políticos que dan lugar a la creación de una norma. Siguiendo con el ejemplo anterior, los pactos preexistentes entre las provincias o los antecedentes constitucionales de los EE. UU. constituyen las fuentes históricas de la Constitución Nacional.

En un último sentido, y este es el que nos interesa desde el punto de vista jurídico, las fuentes del derecho denotan los fenómenos jurídicos que originan derechos y obligaciones en los diferentes sujetos del ordenamiento.

2.- La Ley:

2.1- Concepto: En un sistema continental o romanista de derecho, como el nuestro, la ley la fuente fundamental y primera del derecho: Su preponderancia en es clara respecto al resto de la fuentes, las cuales muchas veces constituyen fuentes solo en los casos en la ley la recepciona expresamente.

Podemos hablar de la ley en un doble sentido, material y formal. Formalmente, se llama ley a toda norma emanada del Poder Legislativo de acuerdo con el procedimiento contemplado en la constitución. Desde un punto de vista material, la ley es toda norma emanada por una autoridad competente. Por consiguiente, en este sentido no solo son leyes las emitidas por el poder ejecutivo, sino también la emanadas por el poder ejecutivo mediante decretos y resoluciones, la constitución los edictos policiales , etc.

Si bien a primera vista la concepción formal aparece como un concepto más restringido que el material, en realidad, es al mismo tiempo más amplio, incluyendo actos del congreso que no constituyen leyes desde el punto de vista material. En este sentido, las leyes emanadas del congreso que realizan declaraciones u otorgan algún tipo de beneficio a personas o personas determinadas, no cumplen con los requisitos de generalidad o de prescripción de conductas obligatorias, circunstancias que no permiten considerarlos leyes en el sentido material.

2.2. Clasificación de las leyes: Tal como vimos con las ramas del derecho objetivo existen diferentes criterios clasificatorios respecto de las leyes

1.- Respecto a su contenido: Tal como analizamos respecto a la ley en sentido formal, no toda norma emanada del órgano legislativo contiene una prescripción de carácter general. Merced a ello, podemos dividir las leyes en:

a.- Autónomas o completas: El contenido lógico se encuentra condensado en una sola preposición lógica. De esta forma la norma legal se basta a si misma a los efectos de definir la cuestión objeto de la misma.

b.- No autónomas o incompletas: Son aquellas normas que no cumplen con los requisitos de las normas autonomas. Entre estas podemos encontrar:

Definiciones legales: Son aquellas normas que no contienen preceptos de conducta, sino simplemente definen uno o varios concepto jurídicos. Ejemplo: La definición de firma electrónica de la ley de Firma digital

Explicativas: Contienen una explicación sobre el alcance de un término utilizado en una tercera norma. Ej. La norma que marca que los plazos de un código de procedimiento se cuentan por días hábiles y no corridos.

Modificadoras o limitativas: Son las que establecen un limite o modificación a otras normas. Ej el art. 14 del Código Civil respecto a la aplicación de la ley extranjera.

2.- Por su estructura: Las leyes pueden ser flexibles o rígidas.

Rígidas: Son aquellas cuya disposición es precisa y concreta, de forma que el su aplicación se limita a la comprobación de los presupuestos de hechos contemplados en su enunciado y su consecuencia es única y claramente fijada por la ley. Ej: *La mayoría de edad se cumple a los 21 años.*

Las Flexibles en cambio, permiten al juez una mayor libertad al momento de la interpretación e integración de la norma. Así por ejemplo el art. 953 del Cod. Civil declara nulas las normas que se oponen a las buenas costumbres. En un mismo sentido, el código civil abunda en términos como *“buen padre de familia”*, *“deber de obrar con prudencia”*, *“caso fortuito o fuerza mayor”*, todas ellas fórmulas elásticas que involucran una influencia determinante de la opinión social, las convicciones religiosas y la propia formación del operador jurídico.

Por el nivel de validez en relación a la voluntad de las personas: Las leyes pueden ser imperativas o supletorias.

Son imperativas aquellas normas que prevalecen sobre la voluntad de las partes, de forma tal que las convenciones entre las partes formuladas en contraposición de las mismas se encuentran teñidas de nulidad. Las mismas pueden estar expresadas en forma de prohibiciones o con un criterio afirmativo pero en ambos casos el efecto es el mismo: Los particulares no pueden apartarse de lo prescrito so pena de tenerse por no escrito lo pactado.

Las leyes supletorias, en cambio, son aquellas que las partes pueden dejar de lado de común acuerdo. Estas normas son comunes en materia constitucional. El objeto de las mismas es suplir las omisiones que las partes hayan realizado en el momento del contrato. Sin embargo, si las partes no encuentran la solución legal de su agrado pueden apartarse de la misma, mediante una cláusula en sentido contrario.

La importancia de la presente clasificación radica en el hecho que en la práctica regula la libertad de las partes al contratar. En este sentido, las normas supletorias han disminuido en los últimos años, merced a la crisis en el concepto de igualdad negocial en los contratos de adhesión y la economía de masas.

3.- La costumbre:

Concepto: Para que exista costumbre, en el sentido otorgado por la ciencia jurídica, deben reunirse dos elementos básicos. Uno material, la repetición de conductas de manera constante y uniforme en una sociedad y el segundo, de carácter subjetivo, como es la percepción de dicha conducta como obligatoria, lo que elimina a los llamados usos o costumbres sociales.

La importancia de la costumbre como fuente de derecho ha variado en función del paso del tiempo. Si bien en un principio, en los ordenamientos más primitivos, constituyó la fuente principal de normas, la evolución social fue dejándola de lado en pos de una formulación escrita de los preceptos sociales. Sin embargo, a partir del siglo XX, la costumbre es nuevamente revalorizada en función de los criterios realistas de interpretación jurídica, lo que da lugar a la recepción en nuestro derecho de dicha fuente.

El código civil argentino regula la costumbre en el art. 17. En su concepción original, la costumbre sólo podía ser fuente en los casos en que la ley la receptara expresamente careciendo de efectos en los casos que se opusiera a esta última o incluso cuando normara cuestiones omitidas por la ley.

Esta solución, si bien se encuentra en concordancia con los principios racionalistas imperantes en la época, no se condice con la realidad social que ya en ese momento existía. Cuestiones como el nombre de las personas y el régimen legal de los sepulcros carecían de regulación legal y se regieron por la costumbre hasta casi sesenta

años después de aprobado el código, lo que tornaba la solución legal en inadecuada.

En 1968, la reforma del código civil realizada por el decreto ley 17711 otorgó fuerza legal a la costumbre en los casos de silencio de la ley. Sin embargo, sigue prohibiendo la costumbre en los casos en que la misma se opone a al texto expreso de la ley.

4.- La jurisprudencia:

4.1 Concepto: El termino se refiere a los fallos de los tribunales judiciales que sirven de precedentes a futuros pronunciamientos⁹.

Para que haya jurisprudencia no es necesario que los precedentes se extiendan en el tiempo, en muchas ocasiones la existencia de un solo pronunciamiento al respecto sienta jurisprudencia: En tales casos se dice que estamos en presencia de un *Leading Case*.

4.2 Su importancia: Sin bien las normas creadas por los jueces son obligatorias, su alcance se limita a las partes intervinientes en el pleito judicial, no siendo oponibles a terceros. En función de ello, cabe preguntarse cómo la jurisprudencia puede tener efectos más allá de los involucrados directos.

En primer lugar la interpretación de una norma judicial no es única: Es el poder judicial quien, en última instancia, delimita el alcance de un texto, terminando cuales de las interpretaciones del enunciado de la ley es el aplicable al fallar en el caso concreto. Atento ello, algunos ius filósofos de la escuela realista americana sostuvieron que *la ley es lo que el juez dice que es*¹⁰.

En segundo lugar esta interpretación no es una constante, sino que varía en función de los cambios tanto en la ciencia jurídica como en la realidad social sobre la cual operan los jueces. La interpretación de la ley por parte de estos, deja entonces de ser un mero ejercicio mecánico y se transforma en una forma de autentica creación jurídica: opera sobre el mismo texto literal pero se aparta de las soluciones hasta ese entonces, creando de hecho una nueva norma jurídica.

Por último, debe tenerse en cuenta que la ley no establece principios de carácter general, de forma tal que solamente se pueden prever un número limitado de casos fácticos de un universo mucho más grande. De esta manera, se produce lo que en derecho se conoce como el fenómeno de las lagunas del derecho: en muchas casos el texto legal nada dice, y es entonces cuando el juez,

⁹ Borda, op cit, pag. 81 sig

¹⁰ Entre ellos podemos citar a Wendell Homes y Hughes, ambos jueces de la suprema corte de Estados Unidos de Norte América.

quien por ley esta obligado a fallar, integra la norma, creando una solución al problema no contemplado legalmente. Su pronunciamiento será entonces creador de derechos y obligaciones no solo para las partes sino también servirá como guía a los demás sujetos del ordenamiento jurídico, quienes pueden prever cuál será el fallo en un caso concreto.

Efectos de la ley con relación al tiempo:

1.- Concepto:

El problema de los efectos de la ley con relación al tiempo involucra dos cuestiones fundamentales a dilucidar: La primera, cuándo una ley comienza a ser obligatoria para los sujetos de derecho. La segunda, si existe la posibilidad de otorgar efectos retroactivos a la ley y en dicho caso, cuales son los límites a dicha actividad.

2.- Fecha de entrada en vigencia:

El art. 2 del código civil determina la obligatoriedad de las leyes a partir de su publicación. El plazo puede variar siendo potestad del legislador fijar un plazo mayor o menor según su conveniencia. Si nada dice, el código civil establece un plazo supletorio de ocho días a contar desde el día siguiente a la publicación en el boletín oficial. Por ejemplo una ley publicada en el boletín oficial el 11 de abril tendrá vigencia recién el 20 de abril inclusive.

El término ley se utiliza en este art. como ley en sentido material, de forma tal que los decretos del poder ejecutivo y las ordenanzas municipales también deben ser publicados. A partir de la ley 16.504 del año 1964 esta publicación sólo es válida si se realiza en el boletín oficial, publicación del estado de carácter diario que recoge las leyes y decretos. Las ordenanzas municipales en cambio son publicitadas en el Boletín Municipal.

Como se puede ver la publicación de una norma reviste singular importancia atento el hecho que a partir de la misma se comienza a contar los plazos para su obligatoriedad. Para la doctrina tradicional esto obedece a que solo a partir de este momento la ley es conocida por la población, premisa que en la realidad, esta lejos de cumplirse: el boletín oficial es leído por pocas personas, por lo que resulta imposible considerar al mismo como un mecanismo efectivo de publicidad. Sin embargo, la necesidad de previsión en las relaciones jurídicas mantiene la ficción jurídica del conocimiento de la ley, más allá de la capacidad de conocimiento real que pueda tenerse.

3.- Aplicación retroactiva de la ley:

Por regla general las relaciones jurídicas no se culminan en un solo instante sino que tienden a mantenerse en el tiempo, de forma tal que la entrada en vigencia de una ley puede modificar los efectos que estas venían teniendo hasta ese momento. Para que estemos frente a una ley retroactiva esta modificación debe darse

respecto a efectos anteriores a la entrada en vigencia de la nueva norma. Por ejemplo, una ley que ordena un aumento de la tasa de interés de un préstamo sería retroactiva en el caso que obligara a los deudores a abonar la diferencia desde el comienzo de la deuda. Si en cambio, simplemente ordenara el aumento para las cuotas que restan, no estaríamos frente a efectos retroactivos sino inmediatos.

El problema de la aplicación retroactiva de la ley fue asociado en la reglamentación original del código civil con el principio de protección de la propiedad privada. De esta manera, el art. 3 de dicho ordenamiento prohibía el efecto retroactivo, en tanto afectara derechos adquiridos.

El problema fundamental de dicha formula que es toda cambio legislativo, en forma mediata o inmediata, implica un avasallamiento de derecho adquirido. A mayor abundamiento, tanto la ley como la jurisprudencia carecían de una determinación precisa del concepto de derecho adquirido, lo que dificultaba sensiblemente la aplicación de la norma. Atento a ello, la ley 17.711 modificó el texto del art. 3 por el siguiente:

A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley, en ningún caso puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

A los contrato en curso de ejecución, no son aplicables las nuevas leyes supletorias.

Analizando el texto de la ley vemos que hay dos hipótesis fundamentales, aludidas en el mismo:

La primera es lo que el texto llama situaciones jurídicas generales, es decir, los derechos regidos por la ley y no por la voluntad de las partes. Como ejemplo podemos citar los derechos reales o las relaciones de familia. En estos casos la ley se aplica desde su entrada en vigencia.

Respecto a las relaciones regidas por la voluntad de las partes debemos diferenciar según el tipo de norma. En el caso de normas imperativas, su aplicación comienza desde su entrada en vigencia. En cambio el caso de normas supletorias, la modificación no tiene efectos respecto a contratos ya iniciados.

El fundamento de esta solución legal es que, como ya vimos, la norma supletoria integra el contrato cuando las partes no dispusieron nada en contrario. Merced a ello, el acuerdo de voluntades se compone por lo que las partes expresamente acordaron con más lo que la ley marca en caso de silencio. La aplicación de una nueva norma en este caso implica una modificación de la voluntad de las partes al contratar, quienes

pudieron haber guardado silencio simplemente por estar de acuerdo con la solución legal al caso. Distinto es el caso de las normas imperativas, atento que, en dicho caso, la ley no permite a las partes apartarse de lo prescrito legalmente y, por ende, la solución debe guarda analogía con lo normado para la primera hipótesis.

Asimismo, el texto de la ley limita el alcance de la retroactividad de la ley a los casos en que no se haya afectado un derecho constitucional. A este respecto es importante señalar que se elimina la referencia al derecho de propiedad y/o los derechos adquiridos que han generado una fuerte controversia jurisprudencial a favor de una mayor precisión doctrinaria. Sin embargo, en función del principio de supremacía constitucional, debe admitirse que en realidad, ninguna ley, retroactiva o no, puede afectar un derecho constitucional.

Ello no significa que los derechos constitucionales son absolutos. La Corte Suprema ha sostenido en repetidas ocasiones¹¹ que todo derecho es susceptible de regulación, mientras que la misma no desnaturalice su esencia o los torne una mera declaración sin efecto jurídico. En función de ello ha aceptado en repetidas ocasiones la constitucionalidad de las llamadas leyes de emergencia, cuestión cuyo análisis excede con creces los objetivos de este trabajo.

¹¹

Al respecto ver los casos Cine Callao, Peralta o Smith.

Elementos de las relaciones jurídicas

1.- Los sujetos: Toda relación jurídica implica necesariamente la existencia de sujetos de derecho, ya sea de existencia física o legal (sociedades, fundaciones, cooperativas o demás casos en que la ley otorga capacidad para ser titular de derechos y obligaciones). Respecto a una relación jurídica determinada podemos clasificar a los sujetos en:

La Partes: Las partes de una relación jurídica son aquellas que por sí o por intermedio de un representante, se han obligado a cumplir cierta conducta o son titulares de un determinado derecho. Debe tenerse en cuenta que, en los casos de actos jurídicos, debe diferenciarse entre las partes y los firmantes u otorgantes del acto: Si bien en la mayoría de los casos ambas figuras coinciden en la misma persona, no necesariamente esto es así, como lo demuestra la figura del mandatario o representante ya sea legal o convencional.

Asimismo se considera partes a los sucesores universales de una persona fallecida. Esto es así porque para nuestro ordenamiento los sucesores de una persona fallecida continúan el lugar jurídico del causante. Sin embargo esta regla tiene excepciones:

1.- En los casos en que la obligación se hubiera realizado teniendo en cuenta las características personales del fallecido. Tal es el caso de la mayoría de las locaciones de obra, particular cuando el encargado de la obra contaba con cualidades particulares que eran definitorias del contrato (ej. El encargo de una obra a un pintor)

2.- En los casos que las partes al momento de contratar hayan definido que al muerte de una de ellas resuelve el contrato. En tal caso, los sucesores, si bien continúan la persona del causante, no están obligados a prestación alguna ya que la misma dejó de existir con el fallecimiento.

3.- Los casos que se acepte la sucesión con el llamado beneficio de inventario. En tal caso los patrimonios del sucesores y el causante no se mezclan y se evita la confusión entre los mismos.

Los terceros: Desde un concepto amplio, puede decirse que un tercero es todo aquel que no es parte de una relación jurídica. Como principio general, los actos realizados por las partes no tiene efectos contra los terceros, salvo en el caso de transmisión de derechos reales, los cuales son oponibles contra cualquier persona, haya o no participado en el acto de cuestión.

2.- La Causa:

La palabra causa tiene en el derecho dos acepciones diferentes: La primera refiere al hecho respecto del cual derivan las obligaciones, ya sean estas un hecho ilícito, la voluntad de las partes o simplemente la misma ley.

La segunda, y es la que nos interesa a los efectos de este apunte, significa el fin que las partes se propusieron al contratar. Según la doctrina más difundida, la causa es el fin inmediato y determinante que las partes han tenido al contratar, es la razón directa y concreta que las partes para la celebración del acto y atento ello, no puede ser ignorada por la contraparte.

Debe igualmente diferenciarse la causa de los meros motivos que las partes tuvieron al contratar. La primera son los fines inmediatos que una persona tuvo al celebrar un acto, la segunda, en cambio, son las motivaciones psicológicas que llevaron a las partes a hacerlo, las cuales no tienen efectos jurídicos inmediatos. Así, por ejemplo, en un contrato de compraventa de inmuebles, la causa es para el vendedor es el pago del precio, en cambio si los motivos puede ser la compra de un inmueble mas grande. Para el derecho, la satisfacción de este motivo ulterior carece de efectos: compre o no el segundo inmueble, la operación es válida.

La principal regulación de la causa, esta dada por los art. 500 y 502 del código civil. Ellos regulan los problemas derivados de la nulidad, o falsedad de la causa y sus efectos jurídicos. El art. 500 establece una presunción de existencia de la causa, aun en los casos en que la misma no este expresada al momento de la obligación. Esto obedece al hecho que por razones de seguridad jurídicas la validez de los negocios jurídicos se presume, siendo carga de quien plantea su nulidad la prueba de dichos extremos.

Sin embargo, puede ser la causa no existe, sea contraria a derecho o existiendo la misma sea falsa. En los dos primeros casos nos encontramos con una relación jurídica sin causa, la cual debe reputarse nula (art. 502). Sin embargo, en el último caso, vemos que si bien la causa manifestada es falsa, puede ocultar otra válida. Tal es el caso de los actos simulados, donde las partes conscientemente crean una causa falsa, normalmente en perjuicio de sus acreedores u otro tercero, para ocultar otra causa real. En tales casos, el ordenamiento sostiene que si la causa real es válida, el acto simulado se mantiene. Esto es de particular importancia respecto a los terceros, toda vez que pueden oponer el acto a los simuladores, si así les conviene.

3.- El Objeto: El concepto de objeto refiere a la cosa o hechos sobre la cual recae la obligación contraída. En otros términos se trata de la prestación debida.

El objeto constituye un elemento fundamental de la relación jurídica, toda vez que no puede entenderse una relación obligacional donde nadie tenga obligación de nada. Sin embargo, no todo objeto es válido, debiendo cumplir lo normado por el art. 953 del Código Civil, el cual expresa:

El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de un acto jurídico o hechos que no sean imposibles, ilícitos contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conforme a esta disposición son nulos como si no tuviesen objeto.

En función del texto del artículo, vemos que el objeto debe cumplir con tres condiciones básicas:

1.- Debe ser Posible: Esta posibilidad física de realizar la prestación debe ser absoluta y no relativa al contratante. Por ejemplo, la obligación de construir una catedral o pintar un retrato puede resultar imposible para una persona no entrenada, pero la obligación sigue siendo válida entre las partes y su incumplimiento conlleva sanciones. En cambio, la prestación “saltar un edificio” es físicamente imposible y debe reputarse nula.

2.- Debe ser lícito: Todo objeto contrario al ordenamiento es nulo. Ello obedece a que el ordenamiento no puede otorgar validez a un acto que niega su vigencia, so pena de caer en un contrasentido lógico.

3.- Debe ser conforme a la moral y las buenas costumbres: Este concepto constituye un standard jurídico, el cual debe evaluarse en el caso concreto. Sin embargo, es conteste la jurisprudencia en calificar estas actividades como contrarias a la moral: La locación de inmuebles para casas de citas, los pactos de retroventa de automotores como garantía de un préstamo¹², los intereses usuarios.

Respecto a los efectos debe tenerse en cuenta si la prestación constituye una parte esencial de la convención o si, por ejemplo en los casos de pactos de retroventa o intereses, estamos frente a un accesorio. Normalmente en el primer caso se decreta la nulidad de toda la convención, mientras que en el segundo, simplemente afecta a la cláusula, dejando la relación jurídica

¹² Es particularmente común, en los casos de préstamos usurarios, la venta al prestamista de un automotor o inmueble como garantía con el agregado de una cláusula de devolución al deudor en caso de cumplimiento y de esta forma evitar la ejecución de la deuda o su discusión judicial. Esta convención accesorio es conocido como pacto de retroventa

Aspectos Legales y Profesionales

Estructura Constitucional

A.- Constitución formal y material:

Cuando en derecho hablamos de estructura constitución en realidad estamos mencionando dos conceptos que, si bien revisten puntos en común, no son idénticos.

La primera aproximación al término constitución nos remite a la existencia de un texto legal sancionado por un órgano particular, la convención constituyente. Este texto mantiene un carácter supra legal, de forma tal que todo el contenido del ordenamiento jurídico se puede derivar del mismo. Las características de la constitución escrita serían las siguientes

- La constitución es una ley
- Esa ley es escrita
- Se encuentra reunida íntegramente en texto único y sistematizado
- Este texto es sancionado por la convención constituyente y no por el poder legislativo.
- Constituye la norma fundamental del ordenamiento jurídico

Sin embargo, si queremos realmente entender cómo funciona el esquema de poder de un estado, no podemos simplemente quedarnos en el análisis del simple texto, siendo necesario estudiar su real aplicación. A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que ciertos estados carecen de constitución escrita, debiendo analizarse los comportamientos sociales como forma de determinar la estructura del estado. Estamos en tal caso ante una constitución en sentido material.

Todos los estados tienen una constitución material, ya que esta constituido o funciona de una manera determinada, aun en los casos en que no exista un texto escrito. Aun en el caso de que exista una constitución escrita, debe tenerse en cuenta que la constitución material excede el contenido de la primera. Esto es así porque aún en el caso de la plena aplicación del contenido

escrito, existen elementos que se incorporan fuera y al margen de la constitución formal, como por ejemplo la jurisprudencia de los tribunales respecto de las cláusulas.

El contenido de la constitución tanto formal como material esta dado por dos grandes campos: el que se refiere al ejercicio del poder, en lo referente a la conformación de los órganos de gobierno, su funcionamiento y capacidades y, en segundo lugar, la posición de los sujetos frente la estado. La primera es la conocida como parte orgánica de la constitución, mientras que la segunda recibe el nombre de parte dogmática.

Puede que la constitución formal y la material coincida, de forma tal que todo el texto constitucional tiene vigencia y aplicación. Sin embargo puede suceder que la constitución material presente discrepancias con la formal. Ello puede suceder porque ciertas cláusulas contenidas en el texto cayeron en desuso, como puede ser la potestad del estado nacional de otorgar patentes de corso (autorización para el ejercicio de la piratería). También puede suceder que la cláusula nunca haya llegado a implementarse, como el caso de la regulación del juicio por jurados.

II.- Principio de supremacía constitucional

Art. 31.- *Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859.*

Hans Kelsen, un catedrático y teórico del derecho vienes, entendía al ordenamiento jurídico como una estructura piramidal en la que la constitución constituye el vértice superior y el fundamento lógico de las restantes normas. Esta visión se encuentra en concordancia con

el artículo transcrito anteriormente, de forma tal que la constitución establece los límites de la normativa que encuentra en ella su justificación.

La supremacía constitucional supone una graduación jerárquica del orden jurídico derivado, que se escalona en planos distintos. Los más altos subordinan a los inferiores y todo el conjunto debe ajustarse al contenido de la constitución.

Cuando una norma inferior contradice al texto constitucional se produce un fenómeno jurídico conocido como inconstitucionalidad. Tales actos se encuentran privados de validez por el ordenamiento jurídico y se reputan nulos, de forma tal de evitar contradecir la estructura lógica que reseñábamos en los párrafos anteriores.

Como consecuencia directa de ello, se hace necesario un mecanismo que permita detectar y declarar las normas inconstitucionales. Tales soluciones se engloban la denominación de *sistemas de control o revisión constitucional*.

Respecto al alcance del control constitucional, por principio, todos los actos y normas, ya sea de particulares o del propio estado, se encuentran sujetos al control constitucional. Sin embargo, cierta doctrina y jurisprudencia admite la existencia de una excepción en los casos de las llamadas “*cuestiones políticas no judiciables*”, las que quedarían fuera del control. Ello no quiere decir que respecto a estas la supremacía constitucional no exista sino que la misma no puede ser ejercida mediante una acción ante el organismo de control.

Algunos autores critican esta concepción por entender que la misma modifica la constitución escrita, introduciendo por vía interpretativa excepciones no contenida en el texto. En realidad que los casos en que se plantea la existencia de cuestiones políticas (Ej. declaraciones de guerra o de estado de sitio) no se esta frente una excepción sino a un limitación propia del mecanismo de control. El organismo de contralor no analiza la oportunidad de la medida sino solamente sino la concordancia con el texto constitucional. Si analizamos por ejemplo la declaración de guerra, existe un control constitucional en referencia al órgano competente para realizarla pero respecto a las razones para la misma toda vez que la constitución nada dice al respecto. Por lo tanto no es que la cuestión este exenta del control

constitucional sino que este no puede avanzar sobre cuestiones que exceden al marco de dicha norma.

Respecto de los mecanismos de control constitucional, los mismos pueden clasificarse según sus características fundamentales de la siguiente manera:

1.- Por el órgano que toma a cargo su control: El mecanismo puede ser político, si es que el órgano encargado permanece en la órbita del poder político. Tal es el caso del Tribunal de Control Constitucional de Francia creado en el año 1958.

Puede asimismo ser jurisdiccional cuando queda en la órbita de la administración de justicia. En tal sentido debe diferenciarse los casos en que la posibilidad de controlar se encuentra otorgadas todos los jueces sin diferenciación del fuero, en cuyo caso el sistema se conoce como difuso, o cuando existe un único organismo encargado de la declaración de inconstitucionalidad, en cuyo caso nos encontramos frente a un sistema concentrado.

2.- Por las vías procesales mediante puede introducirse la cuestión constitucional el sistema puede ser directo en los casos en la demanda tiene por objeto la declaración de inconstitucional de una norma u acto.

Asimismo, puede ser que la cuestión constitucional no sea el objeto principal de la acción sino que constituye una cuestión incidental dentro de una pretensión diferente, con la que mantiene una relación instrumental. Por ejemplo, si se busca la declaración de inconstitucionalidad de una ley que impide expulsión de los deudores morosos dentro de un juicio de desalojo, lo que se busca no es la declaración en sí sino la posibilidad de seguir con el juicio a los efectos de recuperar el inmueble, constituyendo la declaración de inconstitucionalidad un medio y no un fin en sí mismo. En tal caso estaremos frente a un control constitucional indirecto.

3.- Por último, y respecto a los efectos que la declaración pueda tener la misma pueden limitarse al caso bajo estudio (efectos limitados o inter-partes) o extenderse a los casos hipotéticamente comprendidos en la norma (efectos amplios o *erga omnes*). En este último caso, el órgano de contralor puede directamente decretar la nulidad de la

norma o simplemente ordenarle al órgano encargado de su sanción que la derogue.

En el gobierno federal argentino y atento que la constitución prohíbe al poder ejecutivo conocer en causas judiciales, el control constitucional es exclusivamente judicial. Asimismo, este control es potestad de todos los jueces del fuero, los que se expiden por vía incidental con efectos limitados a las partes.

En las constituciones provinciales la cuestión varía, ya que muchos ordenamientos (entre otras la provincia de Buenos Aires) prevén una acción de declaración de inconstitucionalidad directa. En tales casos, la mayoría de las legislaciones reservan el trámite de la pretensión al superior tribunal local (en el caso bonaerense la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires), constituyendo un caso de control constitucional concentrado.

Respecto de los efectos, la mayoría de las legislaciones le otorgan efectos entre partes. Sin embargo, en las constituciones provinciales más modernas se admite los efectos generales. Así, por ejemplo, la constitución de la provincia de Río Negro estipula que al tercer pronunciamiento respecto a la inconstitucionalidad de una norma, el tribunal puede declarar suspendida la aplicación de la norma. Similares sistemas presentan las constituciones de Santiago del Estero y Neuquén, entre otras.

III.- Las Garantías Constitucionales

Art. 43.- *Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.*

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a l

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el

afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.

Las garantías constitucionales son mecanismos de protección jurídica de los particulares frente a estado, a los efectos de que este asegure la vigencia de los derechos consagrados a los ciudadanos.

En un sentido amplio todo el ordenamiento jurídico constituye una garantía del individuo. Sin embargo, en un más específicamente, encontraremos garantías constitucionales en los casos en que el particular puede movilizar la estructura del estado para defender sus derechos.

En el sentido más estricto encontraremos garantías constitucionales en los casos de los procesos judiciales comprendidos en el art. 43 de nuestra constitución nacional: El habeas corpus, amparo y habeas data.

Debe tenerse en cuenta que en todos los casos si bien constituyen acciones de índole constitucional, su regulación procesal queda supeditada a la reglamentación que las provincias decidan darle en sus códigos forma.

El *habeas corpus* es una garantía tradicional que tutela la libertad física o ambulatoria de una persona contra acciones que de cualquier forma la restrinjan en forma arbitraria o sin formas legales. Así, las detenciones, demoras, prohibiciones de circular o arrestos son acciones, que cuando carecen de marco legal que las fundamente, dan pie a la acción.

La misma procede a pedido de un particular o de oficio por el propio juez en los casos en forma arbitraria se restrinja la libertad o de modifiquen las condiciones de detención de una persona. El procedimiento es abreviado pero garantiza la audiencia tanto del damnificado como del organismo denunciado. Esto se hace mediante el llamado auto de habeas corpus, orden judicial en la que se intima al organismo denunciado a informar si la persona se encuentra retenida, las causas de su detención y, en su caso, puede llegar a ordenar la presentación de la misma en sede judicial.

El amparo se asemeja al habeas corpus en cuanto ambos constituyen una vía procesal sumaria a los efectos de asegurar los derechos de los particulares. Sin embargo mientras el habeas corpus protege la libertad ambulatoria, el amparo es una garantía de carácter subsidiario resguardando el conjunto de derechos consagrados por la constitución que carecen de una vía procesal específica.

Otra diferencia es que a diferencia del habeas corpus¹, el amparo no tuvo recepción constitucional hasta el año 1994, siendo básicamente una creación jurisprudencial. Hasta 1957 los tribunales argentinos negaban la procedencia de la figura, basándose en la inexistencia de una regulación específica. Este criterio se modificó con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocido como caso *Siri*, en el que el máximo tribunal admitió la existencia de una acción similar al habeas corpus para salvaguardar derechos no protegidos por el habeas corpus (en este caso la libertad de expresión). En el siguiente año, el tribunal extendió la procedencia de la garantía para los casos de actos realizados por particulares en el caso *Kot*.

En 1966 comenzó con la sanción en el ámbito federal de la ley 16.986 de amparo contra los actos del estado un proceso de reglamentación de la figura que limitó en forma sustancial la utilidad de la misma. En particular impusieron las siguientes condiciones para su procedencia:

1.- El agravio del derecho debe derivar de un acto que sea manifiestamente ilegal o arbitrario: Por lo tanto el amparo no procede en los casos en que el acto atacado se basa en el cumplimiento de normas de carácter general como asimismo cuando el derecho a proteger aparece como dudoso o discutible. Asimismo, la legislación había limitado la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas aunque dicha restricción fue levantada al consagrar el instituto a nivel constitucional en el año 1994.

2.- El amparo no procede en los casos en que exista otras vías o recursos administrativos o judiciales para impugnar el

¹ Si bien no se consagraba expresamente el habeas corpus encontraba su fundamento en el art. 18 de la constitución nacional.

acto. Esto significaba que antes de iniciar el amparo era menester haber agotado todos los recursos y vías previas y que asimismo tampoco pueda remitirse a los procedimientos ordinarios. En este condicionamiento fue modificado sustancialmente por el art. 43 de la Constitución Nacional al sostener que el mismo es procedente en el caso que no exista una vía judicial más idónea. Ello implica que ya no es necesario agotar la vía administrativa para la procedencia del instituto, así como que las vías judiciales que permiten el rechazo deben ser igualmente idóneas para lograr la protección buscada.

Por último, el Habeas Data como garantía tiene su origen en la reforma constitucional de 1994. , constituyendo una figura específica del amparo, destinada a proteger los datos personales.

Atento su importancia, diferiremos su tratamiento hasta el análisis de la ley de bancos de datos.

B.- Forma del Estado y del Gobierno:

Art. 1º.- <i>La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución.</i>
--

El art. 1 de la constitución nacional ha permanecido inalterado desde su formulación en el año 1853. Tal como surge de su texto, declara que la nación argentina establece para su gobierno la forma republica y federal. Cabe preguntarse cuál es entonces el real contenido de la frase.

Si bien tradicionalmente los dos vocablos se utilizaron en forma indistinta, la ciencia política entiende que ambos términos denotan cuestiones diferentes. Cuando hablamos de forma de gobierno nos referimos al modo en que un gobierno ejerce el poder sobre la población sometida a su soberanía. En cambio, en los casos que analizamos las formas del estado estamos frente a las posibles maneras en que el poder se distribuye en el espacio físico de un territorio determinado.

Esta concepción que a primera vista aparece como compleja, es más clara si se analiza un ejemplo práctico. Tomemos el

caso de la sanción de una ley respecto a los delitos informáticos. La forma del estado nos dirá cuál es el estado (nacional, provincial o municipal) competente para sancionarla o, puesto de otra forma, si se trata de una competencia de las provincias o del estado central. En cambio, si estamos analizado el problema desde la óptica de la forma de gobierno, nos estaremos preguntando cuál es órgano dentro del estado competente con capacidad para dictar la norma, la forma en que el mismo se conforma, la permanencia de las personas en dicho cargo, etc.

II.- La forma de Gobierno Monarquía y República.

La mayoría de los autores que se han acercado a la teoría política realizaron clasificaciones respecto de la las formas de gobierno. Aristóteles en su obra Política, plantea la posibilidad de analizar la existencia de formas puras e impuras del gobierno. En este sentido, define que un gobierno en manos de una solo persona en sus formas puras se trataría de una monarquía mientras que una forma degradada de la misma estructura sería una tiranía. Sin, en cambio, el poder se encuentra en manos de unas pocas personas es trataría de una aristocracia, transformándose en una oligarquía en los casos de una forma envilecida. Por último, cuando estamos frente a un ejercicio del poder por parte de toda la población hablaríamos de una democracia o en los casos que la misma se degrade, de demagogia.

El problema básico de la clasificación de Aristóteles consiste en la inclusión dentro de los criterios de valoración un componente axiológico. Dicho de otro modo: El filosofo griego no describe formas de gobierno sino que las valora; un sistema político es una democracia o una demagogia no ya en función de sus propias características internas sino por el juicio de valor, siempre subjetivo, de quien realiza la clasificación.

En tal sentido, hubo que esperar hasta el renacimiento para poder encontrar una clasificación carente de contenido axiológico. Fue el florentino Nicolás Maquiavelo quien en sus obras *“Discurso sobre la primera década de Tito Livio”* y sobre todo *“El Príncipe”* esbozó la ahora separación clásica entre la Monarquía y la República. Y decimos esbozó en un doble sentido: En primer lugar porque las repúblicas del renacimiento

italiano diferían en forma sustancial con lo que hoy conocemos como una república. En segundo lugar, porque el autor no intentó en estos libros realizar un tratado teórico de las formas políticas: Ambas obras se encuentran ancladas en la práctica del poder y no en su deber ser: Maquiavelo no describe un tipo ideal de estructura de gobierno sino que analiza el ejercicio del poder en dos circunstancias diferentes, determinadas por la existencia o no de una figura concentratoria del poder como el príncipe. Atento ello, toda clasificación derivada de la obra del florentino necesariamente carecerá de un encuadre teórico, valiéndose de un básicamente de la generalización de los ejemplos dados en las obras y no en el análisis de las definiciones.

Más allá de ello, podemos decir que existen dos formas básicas de organización del gobierno en la actualidad: La Monarquía y La República. En la primera nos encontraremos frente a un estado encarnado en la figura de una persona determinada (el príncipe, rey o cualquier otro término a utilizar) mientras que en la república el ejercicio del poder se encuentra descorporizado, siendo ejercido por un conjunto de magistraturas en las que las personas que las ocupan resultan indiferentes.

Dentro de la monarquía nos encontramos con dos vertientes básicas, según si el monarca simplemente representa al estado sin ejercer el poder o si el mismo detenta en forma directa la voluntad del estado. En el primero de los casos nos encontraremos frente a una monarquía constitucional, en el segundo, frente a una absoluta. Un ejemplo de monarquía constitucional es la española: La familia Borbon representa al Estado Español y promulga las leyes del ordenamiento (las cuales suelen recibir el nombre de reales decretos), sin embargo el gobierno se encuentra en mano de la sociedad civil quien elige en forma democrática un jefe de gobierno, un parlamento y cuenta con una justicia independiente. El rey, en tales casos, manda pero no gobierna.

Diferente es el caso de una monarquía absoluta. En tales sistemas la voluntad del soberano se confunde con la del estado, permaneciendo el monarca fuera del ordenamiento jurídico que el mismo crea. Tal es el caso de las monarquías europeas del siglo XVIII y en la actualidad de algunos países del oriente medio.

En contraposición la república tal como la conocemos en la actualidad se basa en la idea de un mandato popular ejecutado por personas elegidas como representantes, las que ejercen una magistratura periódica, que existe con prescindencia de quien la detenta. Jurídicamente se caracteriza a través de las siguientes características:

1.- División de Poderes: La función estatal se encuentra dividida entre los distintos poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), los cuales cumplen una actividad específica y limitan las potestades de los otros dos, logrando de esta forma un equilibrio.

2.- Principio de igualdad: El verdadero alcance de este concepto fue formulado por la Corte Suprema de la Nación en su jurisprudencia sosteniendo que la igualdad debe ser entendida como la inexistencia de diferencias irrazonables entre personas que se encuentran en la misma situación de hecho. De esta forma, el principio se quebranta no cuando existe una diferencia de tratamiento entre dos sujetos sino cuando esta diferencia no se sustenta en un principio razonable sino en el prejuicio u otro fundamento arbitrario.

3.- La elección popular de los gobernantes: Como consecuencia de lo anterior, el fundamento del poder de los gobernantes radica en el mandato que la población (sus iguales) le otorga. Así en el caso Alem de 1893, la Corte Suprema sostuvo que *“En nuestro mecanismo institucional, todos los funcionarios públicos son meros mandatarios que ejercen poderes delegados por el pueblo, en quien reside la soberanía originaria”*.

4.- Temporalidad de los cargos de gobierno: es decir es necesaria la renovación periódica de los cargos de gobierno. En realidad esto se da en los poderes legislativos y ejecutivos, ya que los jueces, para salvaguardar su autonomía, mantienen el derecho a la inamovilidad de su cargo mientras dure su buena conducta.

5.- Responsabilidad de los gobernantes: A diferencia de una monarquía absoluta, el gobernante de una república no se encuentra excluido del ordenamiento jurídico que crea, de forma tal que sus actos implican similares consecuencias que las que tendría para una persona particular.

6.- Publicidad de los actos de gobierno: Las leyes y reglamentos emanados del gobierno deben ser conocidos por la población, a la cual esta representa. En la práctica esto se da mediante la publicidad de los debates parlamentarios, así como principalmente mediante la divulgación de las normas en el Boletín Oficial, publicación periódica que recoge las leyes y reglamentos promulgados por el poder ejecutivo.

III.- Formas del estado: Sistemas Unitarios y Federales:

La forma del estado define la manera en que el poder del estado se encuentra distribuido en un territorio determinado. En tal sentido, un estado nacional puede estructurarse como un poder único y central que delega funciones en las administraciones locales una serie de funciones que le competen originariamente. Estaríamos en tal caso ante un estado unitario.

Sin embargo, puede suceder que, por diversos factores, en particular de carácter histórico, el estado nacional se configure en razón de la unión de estados locales ya existentes, los cuales delegan en el poder central una serie menor o mayor de facultades. Tal es el caso de la organización de los cantones suizos o las colonias estadounidenses. En tales casos nos encontramos frente un estado federal.

La consecuencia principal de la forma federal del estado es que las competencias otorgadas al estado nacional tienen un carácter restrictivo. Si las provincias son preexistentes a la nación, toda facultad no delegada le sigue perteneciendo, por lo que las atribuciones del estado central se encuentran circunscritas solamente a lo expresamente autorizado.

Ello no quiere decir que la existencia de un estado federal implique necesariamente una mayor independencia de las administraciones locales. En tal sentido, es la real distribución de potestades entre la nación y las provincias la que define la autonomía política de los gobiernos locales y no la existencia de competencias reservadas. Una simple comparación entre las facultades otorgadas a las comunidades autónomas de

España y las provincias argentinas demostrará que, políticamente, estas últimas se encuentran mucho más limitadas en sus atribuciones a pesar de ser un estado federal.

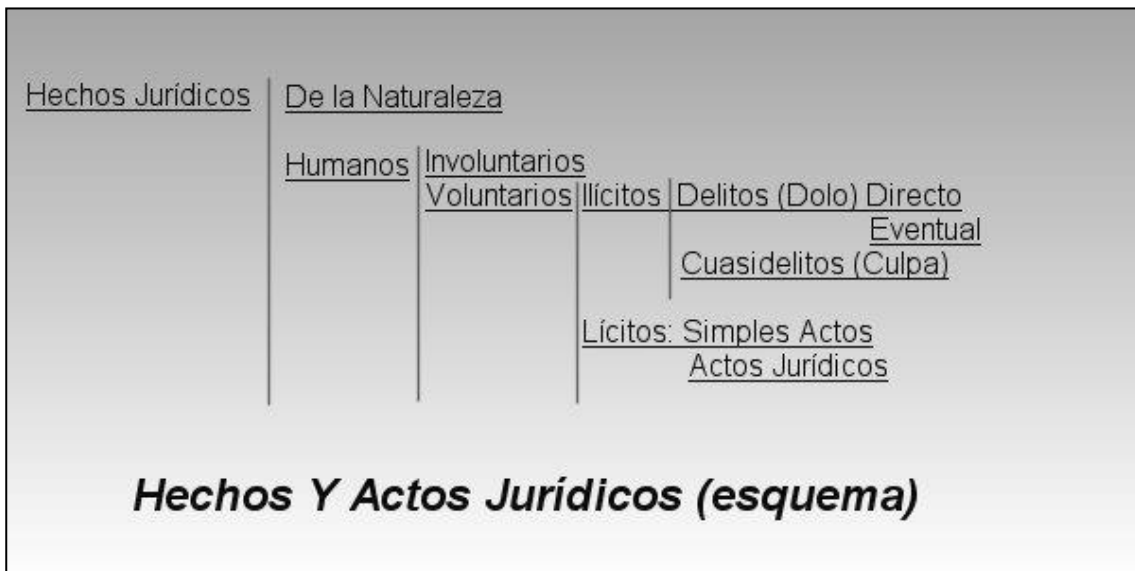
El caso argentino es particular atento la existencia de un esquema original centralizado (el Virreinato del Río de la Plata), el cual por razones políticas desaparece en la década de 1820, persistiendo solo las provincias que la conformaban como forma organizada de ejercicio del poder. Son estas las que, a partir de 1853, se reúnen en congreso general constituyente y dan forma al estado nacional argentino, el cual termina adoptando la forma federal de estado.

La razón fundamental de la lentitud en la organización institucional fue que el período comprendido entre ambas fechas se caracterizó por la disputa entre los partidarios de un estado unitario con sede en Buenos Aires y los que sostenían la necesidad de un estado federal que contemplara las diferencias locales. La solución arribada fue un compromiso entre ambas posiciones, estableciendo un gobierno federal con amplias atribuciones para el estado central

Es por ello que la distribución de competencias entre el gobierno federal y los gobiernos locales en el estado argentino presenta diferencias sustanciales con los ejemplos anteriormente mencionados, marcando una tendencia a la centralización de las funciones. Así, las competencias legislativas de fondo que en la mayoría de los países federales se encuentran en cabeza de los gobiernos locales, en la Argentina son prerrogativa del estado federal, reservándose solamente la legislación de forma. Dicho de otro modo, es potestad del gobierno central el dictado de la legislación civil, comercial o penal, mientras que son las provincias las encargadas de determinar la forma en que los derechos consagrados por estas leyes se ejercen en sede judicial. Sobre esta división de competencias volveremos cuando analicemos la actuación judicial del perito informático.

Aspectos Jurídicos y Profesionales de la informática

Hechos y Actos Jurídicos. Concepto. Forma. Instrumentos Públicos y Privados



1.- Hecho Jurídico. Concepto:

El concepto de hecho jurídico se relaciona directamente con la aprehensión por parte del derecho de los fenómenos generados en el mundo físico. Si bien es indudable que los hechos físicos existen más allá de su referencia en un texto legal, para que podamos hablar de **hechos jurídicos** debemos necesariamente referirnos a **aquellos eventos del mundo real que conllevan una consecuencia jurídica**. Así pues el granizo en un campo no es

de por sí un fenómeno que integre el mundo jurídico. Sin embargo, si constituye una condición a los efectos de la exigibilidad de una obligación (vg. un seguro por daños en una cosecha), entonces, en dicho caso, estamos frente a un hecho jurídico.

Existen muchas clasificaciones de los hechos jurídicos, dependiendo básicamente de cuales son los elementos que se toman como definitorios para realizar la distinción. Sobre el particular, la más interesante es aquella que distingue a los mismos en razón de la calidad de los actores intervinientes en el hecho. Así, es posible distinguir entre **hechos humanos y de la naturaleza**, en función de **si en los mismos se produjo la intervención del hombre o no, respectivamente**.

2.- Hechos voluntarios y involuntarios. El problema del sistema del código:

Ya dentro de los hechos humanos, la principal distinción en función de los efectos jurídicos que produce divide a los hechos en voluntarios e involuntarios. A este respecto, el código civil elabora un sistema que muchos autores critican desde muchos aspectos.

Según el art. 897 del código civil los **hechos voluntarios** son **aquellos que son realizados con discernimiento, intención y libertad**. Y como consecuencia lógica de esta premisa, el art. 900 establece que en los casos de hechos ejecutados sin alguno de estos elementos internos, no se genera obligación alguna.

Sin embargo dicho principio se encuentra muchas veces contradicho por el propio código. Por ejemplo, son numerosos los casos en que estamos frente a actos realizados sin intención a los cuales se les otorgan efectos jurídicos. Tal es el caso de la hipótesis del error no excusable, hipótesis en la cual la intención se encuentra viciada por el desconocimiento de las reales circunstancias de hecho. El hecho que este desconocimiento deba imputarse a la torpeza del autor del acto, no impide considerar que estamos frente a un apartamiento del principio general

Respecto a los elementos podemos definir al **discernimiento** como la **capacidad de analizar y comprender las acciones emprendidas**. A este

respecto el Código no define la figura pero en el art. 921 establece que actos se entenderán que carecen de ella de la siguiente manera: *“Los actos serán reputados hechos sin discernimiento si fueran actos lícitos practicados por menores impúberes o actos ilícitos realizados por menores de 10 años, como así los actos de los dementes que no fueran practicados en intervalos lúcidos y los practicados por los que, por cualquier accidente, están sin uso de razón”*.

Siendo el discernimiento una cuestión psicológica de tan difícil prueba, era necesario la fijación de una regla general que permitiera definir cuando existe o no. Sin embargo, la realidad y el mismo código muchas veces se apartan nuevamente de estos principios. Cualquier niño de nueve años tiene plena comprensión de sus acciones al momento de comprar golosinas o tomar un colectivo. En el sentido opuesto y en caso de las personas en estado de ebriedad, el ordenamiento las hace responsables de sus acciones, a menos que estemos frente a un caso de intoxicación involuntaria. Esta solución, si bien puede considerar razonable y hasta justa, plantea un claro distanciamiento del principio de la falta de efectos de los actos sin discernimiento.

La intención en cambio es **la pretensión de lograr los resultados naturales derivados del acto que se realiza**. De esta forma, la intención involucra la representación de un resultado en el fuero íntimo de la persona y la aceptación del mismo. En esta definición adquiere mayor precisión cuando analizamos los vicios de los que puede adolecer: El error y el dolo en la voluntad.

Existe error en los casos en que el sujeto desconozca las circunstancias de hecho que rodean al hecho voluntario, de forma tal que la intención desaparece atento que el sujeto carece de la información necesaria a los efectos de prever las consecuencias de sus actos. Tal es el caso de identidades equivocadas entre los contratantes o en la hipótesis de error en las calidades del objeto de un convenio.

En el caso del dolo, estamos ante un caso de inducción al error en perjuicio del autor del hecho voluntario. Aplicada a los vicios en los actos jurídicos, la palabra dolo es utilizada a los efectos de referir a la actividad tendiente a engañar a un sujeto de derecho a los efectos que realice una actividad determinada. Al igual que en el caso anterior, el autor del acto carece de información que le permita tomar una decisión fundada, importando

entonces un vicio en la intención. Los ejemplos clásicos de dolo son el engaño en las estado jurídico de un inmueble, ocultando la constitución de hipotecas o la existencia de otros boletos de compraventa.

El código civil en este caso también se aparta del principio expresado con carácter general, estableciendo que si el dolo es recíproco, el acto es válido. El fundamento del dicha regla es evitar que los sujetos de derecho puedan alegar su propia torpeza y evitar entonces llevar a los estrados judiciales una discusión que es, básicamente, una discusión entre dos tramposos; sin embargo vemos aquí otra excepción al precepto general

La libertad, en cambio se relaciona con **la capacidad del sujeto de optar por la realización o no del hecho**. Se sobreentiende que a los efectos de que un hecho se reputa voluntario, es necesario que el sujeto pueda elegir realizarlo o no.

La violencia como vicio de los actos jurídicos, se encuentra directamente relacionado con la libertad o por lo menos con su falta. A este respecto, y refiriéndose siempre a los vicios de los hechos voluntarios, el código civil define a la violencia como la amenaza cierta o inminente que afecta al autor del acto, impidiéndole tomar una decisión independiente. Es indiferente entonces si la violencia es física o se concreta mediante una amenaza: en ambos casos el autor del acto se encuentra coaccionado y carece por tanto de capacidad para decidir.

3.- Actos Lícitos e ilícitos: El dolo y la culpa:

Ya dentro de los hechos humanos voluntarios podemos clasificar a los mismos en función de si los mismo respetan o no el ordenamiento jurídico. Así podemos entonces hablar de hechos lícitos o ilícitos.

Para que existe un **hecho ilícito desde el punto de vista del derecho civil**, es necesario la concurrencia de **tres elementos fundamentales**: **1.- Que el mismo sea contrario a la ley** **2.- Que sea culpable.** **3.- Que haya ocasionado un daño a los terceros.**

Debe tenerse en cuenta que para el derecho civil mientras que no exista un tercero damnificado, no se configura un delito resarcible, atento la

necesidad de existencia de un acreedor para configurar cualquier obligación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicho daño no necesariamente debe ser efectivo e incluso el requisito se cumple con un daño meramente potencial. Así pues, la mera pérdida de chances constituye un daño posible de configurar un acto ilícito civil.

Respecto a la culpabilidad los actos ilícitos pueden derivarse de la culpa o dolo del actor. El primer caso, el evento dañoso se produce sin mediar intención sino que el daño se produce por la realización del daño se produce por la omisión de las reglas del arte o la negligencia en el obrar. Así, el código civil reputa voluntarios a estos actos a pesar de la falta de intención de dañar. La razón de esto es que, si bien la intención no estaba dirigida a producir un daño, la misma estaba dirigida a realizar un acto que, por la falta de una mínima precaución, ha causado un daño.

El dolo, en cambio, presupone un intención de dañar o por lo menos una falta de preocupación por el resultado. En el primer caso, nos encontraremos frente a un dolo simple, mientras que en el segundo, frente a un dolo eventual. La diferencia entre el dolo eventual y la culpa se establece en la ausencia de representación del resultado: si ha existido representación del mismo, siempre nos encontraremos en el territorio del dolo, mientras que si el autor del acto entendió que el resultado no se produciría, estamos en el territorio de la culpa.

En el sistema del Código, se conocen como delitos a los hechos ilícitos realizados mediante dolo y como cuasidelitos a los culposos. Esta diferenciación teórica tiene implicancias prácticas en cuanto conllevan algunos efectos diferentes entre una y otra

Si el hecho es culposo, el autor es no responde por la consecuencias casuales de los actos, lo que si hace en el caso de que haya dolo y el autor las tuviera en cuenta al realizar el acto. Esta diferencia en realidad pierde importancia en la práctica, toda vez que resulta particularmente difícil la determinación del fuero íntimo del autor.

En segundo lugar, en el caso de delitos, el coautor que hubiera efectivamente abonado al indemnización, carece de acción a los efectos de reclamar la parte al resto, limitación de no existe en el caso de la culpa.

Por último, tratándose de un cuasidelito, el juez tiene la potestad de reducir la indemnización atento el estado patrimonial del condenado, circunstancia que no se da en los delitos.

4.- Los actos Jurídicos. Concepto. Clasificación.

Dentro de la categoría de los hechos lícitos existe uno que reviste particular importancia para el derecho, atento que permiten establecer las distintas relaciones jurídicas entre los particulares.

A este respecto el art. 944 del código civil argentino define a los **actos jurídicos** como “**los voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos**”.

De esta definición se desprende que los elementos propios de los actos jurídicos son los siguientes: **1.- Son actos voluntarios 2.- Son lícitos 3.- Tienen por fin inmediato la producción de efectos jurídicos.**

Esta última característica constituye un elemento diferenciador con el resto de los actos lícitos. Así, en el resto de los actos voluntarios las partes no tienen la intención de generar una relación jurídica, la cual sucede simplemente por imperio de la ley. Por ejemplo, el acto de alambrar un campo no tiene por objeto la generación de una relación jurídica sino básicamente el mas pedestre de evitar el extravío del ganado que allí pasta pero más allá de ello constituye un acto posesorio contemplado por la ley. En cambio la celebración de cualquier compraventa, aún mas la simple como puede ser la adquisición de un paquete de cigarrillos tiene por objeto la generación de derechos (la entrega de los cigarrillos para el comprador y la percepción del precio por parte del kiosquero).

Clasificación: A los efectos de ordenar la compleja trama de los actos jurídicos, se los ha clasificado con diversos criterios:

1.- Entre vivos y de última voluntad: Los actos entre vivos no dependen del fallecimiento de quien los otorga. En cambio, los actos de última voluntad producen efectos después del deceso de aquellos cuya voluntad emana. El ejemplo clásico de este último tipo de acto es el testamento.

2.- Actos Formales y No Formales: Actos formales son aquellos cuya existencia o eficacia se encuentran supeditados al cumplimiento de ciertas formas definidas de antemano. En sentido contrario, en caso de ausencia de prescripción, nos encontramos ante un acto no formal.

3.- Actos de administración y de disposición o enajenación: Acto de administración es aquel que tiende a mantener la integridad de su patrimonio o aumentarlo mediante una explotación normal de los bienes que componen a este último. El acto de disposición, en cambio constituye un cambio significativo en la composición patrimonial, de forma tal que se produce una operación extraordinaria que modifica en forma sustancial los bienes de una persona.

Esta clasificación constituye un criterio económico más que jurídico: Un mismo acto puede constituir un acto de administración para una persona y de disposición para una segunda. Así, por ejemplo la venta de un inmueble es un acto de disposición para la mayoría de las persona, pero constituye un acto de administración para un inversor inmobiliario.

4.- Actos jurídicos principales y accesorios: Son actos principales aquellos cuya existencia no se encuentra supeditada a ningún otro acto. Los accesorios, en cambio, encuentran su razón de ser en un acto al cual complementan y sin el cual, carecen de significado. En caso típico de esta última clase es la constitución de fianzas de un contrato de alquiler, de forma de tal que la nulidad de contrato de locación hace caer la garantía dada por la fianza.

Elementos y estructura de los actos jurídicos: Remisión: Los elementos de un acto jurídicos son los mismos que podemos encontrar en la relación jurídica: Sujeto, objeto y causa, de forma tal que remitimos para su estudio a lo analizado oportunamente en el apunte pasado.

4.- Forma de los actos jurídicos. Concepto. Formas solemnes y no solemnes.

Concepto. Evolución histórica: Tal como se explicó al analizar la clasificación de los actos jurídicos, la formalidad de estos últimos refiere a la obligación o no de respetar ciertas actividades normadas por el ordenamiento jurídico.

Las formalidades en los actos jurídicos existen desde el principio del derecho, en particular en las sociedades más primitivas. El derecho romano prescribía formalidades específicas para casi todos los actos jurídicos que se realizaban en el imperio. Estas formalidades constituían un requisito ineludible para la validez del acto, los que no podían ser sustituidas por la prueba de la voluntad de las partes. La razón de ellos estaba básicamente en la escasa educación de la media de la población: La existencia de una mayoría analfabeta hacía imposible la utilización de una forma escrita de preservación de los actos, debiendo recaer en la utilización de los testigos para la prueba. De esta forma, la utilización de solemnidades para la realización de las transacciones jurídicas permitía a los testigos la posibilidad de recordar el acto años después ante su carácter extraordinario.

En la época clásica, cuya consagración se encuentra en el código francés de 1800, se rebeló contra este extremado formalismo, al que antepuso la voluntad de las partes como elemento esencial para la existencia del acto jurídico. Esto obedeció a circunstancias históricas que hicieron necesario abandonar las solemnidades, principalmente el aumento del tráfico jurídico y el analfabetismo entre la población, lo que redundó en un mayor cantidad de actos y la posibilidad de utilizar el soporte papel para dejar sentado el negocio jurídico.

Sin embargo, el derecho moderno ha retornado, por lo menos parcialmente, al formalismo. Las relaciones jurídicas se han hecho tan múltiples y complejas que hacen necesario ordenarlas y evitar los inconvenientes derivados de la imprecisión y la ligereza. Asimismo, el crecimiento de los centros urbanos hace que los mecanismo de publicidad decimonónicos carezcan de efectividad. Esto es evidente respecto a la propiedad de los inmuebles, automotores y otros bienes muebles como caballos pura sangre o embarcaciones, donde la seguridad del tráfico jurídico hace necesario la confección de registros públicos que permitan a los terceros la identidad de los propietarios.

Sin embargo, este formalismo no constituye requisito de existencia como en lo fue en el derecho romano, sino que se otorga en beneficio de las partes, y en particular, de los terceros. Así, esta diferencia teórica implica una diferencia fundamental respecto a los efectos de la falta de cumplimiento de las

solemnidades del acto: En este caso, lo que normalmente esta en duda es la prueba del derecho o su efecto frente a los terceros pero no su existencia.

Esta última diferencia guarda directa relación con la clasificación que puede realizarse respecto a los actos formales en solemnes y no solemnes. Son **actos solemnes aquellos cuya inobservancia de las formas conlleva la nulidad del acto**. En cambio las prescripciones de los **no solemnes no constituyen una condición necesaria del acto, por lo que su ausencia solo afecta la prueba del mismo y su oponibilidad a los terceros**.

En caso que la ley nada diga respecto a si el acto es solemne o no, debe estarse por la negativa. El fundamento de dicha regla estriba en el hecho que esta solución se acerca más al concepto moderno de formalidad, así como permite la validez del acto, evitando de esta forma la nulidad del mismo, la cual debe ser siempre de interpretación restrictiva.

5.- El instrumento Privado y Publico:

El instrumento privado:

Concepto. Requisitos formales: Se denominan instrumentos privados **a aquellos instrumentos que son otorgados por las partes sin mediar intervención del oficial público.**

Respecto a ellos, el principio que impera es la libertad de las formas respecto a su confección y su otorgamiento. Es indiferente en realidad cual es el papel sobre el cual se realizan, la utilización de tinta o grafito o incluso cuál es el idioma utilizado para su redacción.

El principio de la libertad de las formas solo tiene dos límites: La firma y el doble ejemplar.

La firma es un elemento esencial de la validez del instrumento privado. Recién cuando la misma se estampa la misma en el instrumento podemos decir que la manifestación de voluntad de la parte esta completa. Normalmente, la firma **es la manera habitual que una persona escribe su nombre y apellido con el objeto de asumir las responsabilidades derivadas del documento suscrito**; sin embargo, muchas veces la repetición o la simple costumbre hacen que sea imposible distinguir las letras que componen el verdadero nombre. En estos casos, el código marca que basta simplemente el

carácter de habitualidad para considerar cumplido el requisito. En el mismo sentido, pero en este caso solamente restringido a actos entre vivos, el carácter de habitualidad puede caer en los casos en que se ha logrado probar que era la intención del firmante suscribir dicha manifestación de voluntad.

Respecto a la utilización de siglas u otros signos o caracteres, el Código Civil en el art. 1012 establece que no son un reemplazo válido para la escritura del nombre. El fundamento de dicha disposición se encuentra en el peligro de abuso en perjuicio de personas analfabetas. Sin embargo y en lo que respecta a las personas que pueden darse a entender por escrito, la Cámara Comercial de la Capital entendió que un documento suscrito mediante el uso de iniciales es válido, si esta era la forma habitual de firmar de su autor.

Con respecto a la impresión digital, la jurisprudencia es contradictoria, Algunos tribunales se inclinan a aceptarla con restricciones, mientras que otros la rechazan de plano. En realidad, debe diferenciarse según la circunstancia de que el suscribiente sepa leer y escribir o no. En este último caso, debe rechazarse la impresión digital toda vez que, al igual que el mero dibujo al final del instrumento, no permite asegurar que el firmante comprendió cabalmente el negocio jurídico al que adhiere. En cambio, en el caso de personas que se dan a entender por escrito, la impresión digital sería válida para el caso de actos entre vivos, tal como la solución adoptada en el párrafo anterior.

El requisito del doble ejemplar encuentra su fundamento en el art. 1021 del Código Civil que ordena: *Los actos que contengan convenciones perfectamente bilaterales deben ser redactados en tantos originales como partes haya con un interés distinto.*

Esta exigencia formal tiene por objeto poner a las partes en igualdad de condiciones a los efectos de la prueba del acto: La ausencia de cumplimiento pondría entonces en ventaja a la poseedora del instrumento respecto de la otra.

La formalidad del doble ejemplar es de orden público: Las partes no pueden renunciar a la misma y sólo pueden suplirla mediante las formas establecidas por la ley. Para su cumplimiento, deben otorgarse tantas copias como partes haya en el contrato: sin embargo, cada ejemplar no necesariamente debe llevar la firma de todos los contratantes sino que basta con que este suscrito por la contraparte .

Existen algunos casos excepcionales donde el requisito del doble ejemplar no se requiere: 1.- En el caso que una de las partes ya hubiera cumplido con la totalidad de sus obligaciones al momento de la firma del acto (ej si se pagara el precio de una compraventa la firma del contrato): en tal caso la acreedora de la misma carecería de interés en obtener la copia. 2.- En caso que ambas partes después de la redacción del ejemplar hubieran realizado cumplimientos parciales del contrato. 3.- En el caso que se hubiera resuelto por ambas depositar en un tercero (por ejemplo, un escribano) el único ejemplar, siendo este entonces el encargado de la conservación del instrumento.

En caso de falta del doble ejemplar, esto trae aparejada la nulidad del instrumento peor no la del acto en si, el cual puede ser probado por cualquier otro medio de prueba.

La fuerza probatoria: A diferencia de los instrumentos públicos, que gozan de presunción de autenticidad, **los instrumentos privados necesitan el reconocimiento de quien lo suscribió para obtener capacidad probatoria.**

A dichos efectos el art. 1031 del código civil marca que en el caso del firmante de un documento, es obligación el reconocimiento del mismo en caso de ser presentado en juicio. Debe tenerse en cuenta que, en caso de desconocimiento, el documento no queda anulado sino que el juez debe ordenar su cotejo por parte de un perito calígrafo a los efectos de comparar su autenticidad con un cuerpo de escritura realizado al efecto o en caso de no poder realizarse con alguna firma indubitada como las consignadas en un registro bancario o administrativo.

Esta regla tiene una excepción en el caso de firmas certificadas mediante escribano público: En este caso, el oficial público da fe de la autoría de la firma y por tanto no basta con el mero desconocimiento de la misma sino que es necesario realizar un procedimiento de querrela de falsedad a los efectos de demostrar la falsificación.

Una vez comprobada la autenticidad de la firma o en caso de reconocimiento por parte de su autor los efectos varían dependiendo de si estamos frente a las partes o a terceros.

Respecto a las partes, el instrumento hace fe pública respecto al contenido material del mismo: Por ende, a los efectos de probar la

falsificación o adulteración del texto, es necesario proceder a realizar una querrela de falsedad.

En cambio en lo que respecta a las manifestaciones vertidas en el documento, el reconocimiento de firma solamente hace fe hasta prueba en contrario. Atento ello, las afirmaciones de una de las partes respecto al carácter de deudor o la realización de un pago caen simplemente con la presentación de un contradocumento, testigos, o cualquier otro medio de prueba de que intente valerse.

Respecto a los terceros, los instrumentos privados tienen la misma fuerza probatoria que con respecto a las partes solamente después de obtener fecha cierta. De esta forma aun cuando se reconozca la firma, la fecha que se podrá oponer a los terceros será la de la realización de alguno de los actos contemplados en el art. 1035 del Código Civil. Estos son:

- 1.- La presentación en juicio o cualquier autoridad administrativa a los efectos de su archivo.
- 2.- La de su reconocimiento ante un escribano y dos testigos que los firmen
- 3.- La transcripción en cualquier registro
- 4.- El fallecimiento de una de las partes o intervinientes en el acto.

Los Instrumentos Públicos

1- Concepto y requisitos: Según la definición clásica el instrumento público es otorgado con intervención de un oficial público, con las formalidades que la ley establece. Sin embargo, el art. 979 del Código Civil establece el carácter de instrumento público a casos en que no existe intervención de un oficial público. En verdad, **lo que confiere a un instrumento su calidad de público es su autenticidad:** a diferencia de un instrumento privado, **prueban por si mismos la veracidad de su otorgamiento y integridad material sin necesidad de reconocimiento.**

Respecto a los requisitos para que estemos ante un instrumento público ç, podemos nombrar los siguientes:

1.- Intervención de un Oficial Público: Si bien no puede decirse que es una nota definitoria del instrumento, la intervención del oficial público constituye la regla general de los mismos. Solamente en casos excepcionales, el

ordenamiento se aparta de dicho requisito y al hacerlo, es normal la exigencia de mayores requisitos formales a los efectos de mantener la seriedad y solemnidad del acto.

El oficial publico, a los efectos de la eficacia del acto, debe cumplir con una doble competencia. En un aspecto funcional, debe estar legalmente nombrado por la autoridad competente para ejercer el cargo y su capacidad de otorgar el acto se halla circunscripta a las funciones derivadas del mismo. De esta forma, si bien un secretario de juzgado puede otorgar instrumentos públicos, solamente puede hacerlo para el caso de actos sucedidos en un procedimiento judicial en su cargo. Sin embargo, en el caso de que la persona nombrada no cumpliera los requisitos para el cargo los actos otorgados por el mismo son válidos, atento el hecho de que las partes no tienen porque sufrir los perjuicios del descuido estatal en el nombramiento.

Desde el punto de vista territorial, el oficial público sobre puede otorgar instrumentos en la jurisdicción territorial de la que es competente. Esta es la razón fundamental por la cual es requisito de todo instrumento público el lugar de celebración.

2.- Cumplimiento de las formalidades legales. Dichas formalidades varían según el instrumento de que se trate. Sin embargo, hay una que es común a todos y es la firma, la cual reviste características particulares. En este sentido el art. 988 del código civil requiere que el instrumento este firmado por todos los participantes, bajo pena de nulidad. En caso de ausencia de una de las firmas, el acto nunca se terminó y el mismo no puede ser hecho valer ni siquiera por quien no lo firmó en contra de quien si lo hizo. Sin embargo, y en caso de que alguna de las partes no pueda o no sepa firmar, el oficial público puede dejar constancia de este hecho y permitir que otra persona firme por él.

La enumeración legal: El art. 979 del código civil enumera las distintas clases de instrumentos públicos. Dicha enumeración es cerrada, de forma tal que no existen otros mas allá de los incluidos en el artículo.

Entre las diferentes clases, es necesario mencionar las siguientes:

1.- Las escrituras publicas realizadas por escribanos públicos en sus libros de protocolos: Esta es la forma mas común y quizás la más importante de los instrumentos públicos. El libro de protocolo al que se hace referencia es el libro

que todo escribano debe llevar por obligación legal en el que se anotan las escrituras públicas en forma consecutiva, de forma tal que las mismas quedan ordenadas por orden cronológico y de esta forma impedir que se fragüe una fecha falsa en una escritura.

2.- *Las actas judiciales hechas por los expedientes por los respectivos escribanos y firmadas por las partes, en los casos y en la forma que determinen las leyes de procedimiento.* Los escribanos de que habla el art. son los secretarios del juzgado o también conocidos como actuarios. Si bien el texto habla de que las mismas son confeccionadas por el secretario, normalmente este solo firma la misma, siendo su autor un empleado del juzgado. Dicha circunstancia, sin embargo, no obsta para la validez del acto.

3.- *Los asientos de los libros de los corredores en los casos y en la forma que determine el Código de Comercio:* En realidad salvo un ignoto caso referido al fletamiento marítimo, el código de comercio no otorga carácter de instrumento público a los libros de comercio.

4.- *Los asientos parroquiales:* Se refiere a los asientos de nacimientos, matrimonio o muerte de una persona, los cuales antiguamente se asentaban en las parroquias. En realidad desde 1880 con la sanción de la ley de matrimonio civil este inciso ha caído en desuso, ya que dicha tarea es realizada hoy en día por el estado.

5.- *Cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieran determinado.* Este inciso es prácticamente ilimitada y permite englobar en ella, aquellos casos no contemplados por el art. Entre los más importantes podemos mencionar: Los informes del registro de la propiedad, las partidas del registro civil, las actas de sesión legislativa, las notificaciones judiciales, los telegramas colacionados, los billetes de lotería, ect.

Valor probatorio: Los Instrumentos públicos gozan de autenticidad, es decir que prueban su contenido por si mismo sin necesidad del reconocimiento posterior de las partes intervinientes.

No obstante ello, no todas las cláusulas gozan de la misma fe: La ley distingue , en realidad tres hipótesis diferentes:

Hechos cumplidos por ante el oficial público: Respecto de ellos, el instrumento hace plena fe hasta su impugnación.

Sin embargo, la fe debida a la palabra de un oficial público no se extiende a todas sus afirmaciones, sino solamente a aquellas que él ha visto u oído. Así por ejemplo las apreciaciones personales del escribano respecto a la salud de los contratantes carecen de fe, atento que el escribano no es un perito o especialista que pueda dar pruebas de la veracidad de dichas afirmaciones

Las manifestaciones de las partes: Las manifestaciones de las partes respecto a actos anteriores, pagos realizados fuera de la presencia del oficial público o cualquier otra cuestión, **hacen fe pero sólo hasta que se realiza cualquier prueba en contrario.** Es decir que si bien es necesaria la realización de prueba en contrario, no es necesario el procedimiento de impugnación derivado de la fe pública.

Debe advertirse que aquí estamos hablando del contenido de las manifestaciones y no del hecho mismo de haberlas realizado, circunstancia que, al haber pasado por ante el oficial público, mantienen fe pública.

Simple enunciaciones: Tradicionalmente, se separa el contenido de un acto jurídico entre las disposiciones del negocio y las simples enunciaciones que lo acompañan, las cuales **constituyen detalles que las partes han dejado deslizar en el convenio para una mejor interpretación.** Así, por ejemplo, decir que el precio de un bien en una compraventa asciende a una suma determinada y que se paga al contado, constituye una disposición, mientras que manifestar que el dinero proviene de un crédito del Banco Provincia de Buenos Aires, es una mera enunciación.

Sin embargo esta diferencia que aparece clara en la teoría, es mucho más confusa en el momento de aplicarla a la realidad negocial. Por tanto, a los efectos de dirimir la cuestión, el Código Civil define **que en los casos que las simples enunciaciones están directamente vinculadas con el objeto del contrato, las mismas hacen plena fe respecto a las partes y los terceros.**

Respecto a **aquellas que no están directamente vinculadas con el objeto del contrato**, el código nada dice, pero la doctrina y la jurisprudencia ha entendido que **las mismas hacen plena fe respecto a las partes pero son inoponibles a los terceros.**

Impugnación del Instrumento Público: A los efectos de la impugnación de los instrumentos públicos, **la parte que lo intenta tiene la opción de intentar la vía civil por readgución de falsedad o iniciar la acción penal por falsificación de un instrumento público.**

En el caso de la acción penal, la misma persigue la condena del oficial que otorgó el instrumento público, y de manera secundaria, lograr cosa juzgada acerca de la falsedad del acto en si o sus contenidos.

En el caso de una acción civil la misma se debe dirigir contra todos los intervinientes en el acto y se puede iniciar como una acción independiente o en un juicio ya iniciado, mediante lo que se conoce como incidente. La única limitación que tiene esta vía es que no puede presentarse en los llamados juicios ejecutivos, ya que los mismos no permiten una discusión amplia de las cuestiones sujetas a su decisión.

Clase 1

Contratos

I.- El concepto de contrato:

Art. 1137: *“Habra contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos”*

De la propia definición del código civil plantea una característica fundamental del contrato: Implica un acuerdo de voluntades, principio de la que se derivan las siguientes consecuencias:

1.- Es necesaria la concurrencia de dos o mas personas: El ordenamiento argentino, a diferencias de otros regímenes como el alemán, no prevé la existencia de un auto contrato: Es, por tanto, condición esencial la existencia de dos o mas personas para que exista contrato.

2.- Cada una de estas personas debe realizar una manifestación de voluntad: Cada una de estas manifestaciones de voluntad por separado constituye un acto jurídico con las características y requisitos vistos en la ficha anterior.

3.- Estas manifestaciones deben ser concurrentes: Cada una de las personas debe realizar una manifestación de voluntad tendiente a la generación de un contrato determinado, ya sea realizando una oferta o aceptándola. Esta premisa que en principio parece redundante adquiere relevancia en los casos en que por error o dolo alguna de las partes consiente un negocio jurídico diferente al aceptado por la otra, hecho que puede derivar en conflictos judiciales.

4.- Ambas manifestaciones deben tender a la generación o modificación de derechos y obligaciones: Algunos autores (vg Guillermo Borda) han criticado la redacción del art. 1137 toda vez que según el mismo podría considerarse

contrato manifestaciones tendientes no a generar sino extinguir a los derechos y obligaciones. Este último negocio jurídico, si bien guarda similitudes con el objeto del presente apunte, constituye según la doctrina un instituto diferente al que se denomina *distracto*.

II.- Evolución Histórica del contrato:

La evolución histórica resulta importante en tanto en cuanto permite analizar la existencia de una relación entre las formas contractuales, las relaciones de poder y la circulación de bienes y servicios a la que estos dan cobertura jurídica.

Originariamente y según la concepción romana, la voluntad de las partes no resultaba el elemento esencial del instituto: La forma y la existencia de un reconocimiento del negocio por parte del estado constituían las condiciones necesarias para la existencia de una convención exigible: Era el príncipe quien otorgaba la obligatoriedad a los acuerdos, los que debían adecuarse a tipos determinados y cumplir con las formalidades establecidas para los mismos. Recién en tiempos del emperador bizantino Justiano se previó la existencia de una acción judicial a los efectos de forzar el cumplimiento de los acuerdos entre las partes que no estuvieran previstos por el ordenamiento, pero siempre y cuando una de las partes haya realizado la prestación obligada, circunstancia que hace pensar que el fundamento estribaría más en una cuestión de equidad que de respeto de la voluntad de las partes.

Hubo que esperar hasta la revolución francesa para que la voluntad tuviera capacidad de generar derechos y obligaciones. Históricamente, este fenómeno encuentra su base en el desplazamiento del poder económico de los estados centrales o feudales hacia las burguesías comerciales, con la consiguiente intención de estas últimas de evitar el control gubernamental de sus transacciones.

En la concepción francesa, la voluntad constituye la base y el fundamento de la obligación derivada de los contratos. Si los hombres son naturalmente libres e iguales, deben tener derecho a determinar sus relaciones personales sin intervención del estado, con excepción de los casos de incumplimiento. En esta visión, la función del derecho se limita a dar fuerza

obligatoria a lo que las partes libremente acuerdan, existiendo simplemente como mecanismo de cumplimiento forzoso en los casos de obligados reticentes.

Sin embargo, dicha concepción conlleva una contradicción fundamental en tanto confunde la igualdad jurídica con la económica, otorgando similar capacidad negocial a sujetos materialmente disímiles. Dicho de otro modo: Si la igualdad puede sostenerse como posibles entre dos comerciantes del siglo XVIII, es indudablemente insostenible en una economía de masas, en la que el sujeto se encuentra frente a operadores jurídicos con capacidad económica de imponer sus propias condiciones al contrato.

En el mismo sentido el simple acuerdo de voluntades choca con una realidad básica del siglo XIX y más aun en el siglo XX: los grandes conglomerados urbanos hacen imposible el conocimiento personal de cada una de las transacciones realizadas, circunstancia que impide la seguridad jurídica respecto a las operaciones, lo que deriva en la posibilidad cierta de perjuicios de terceros, quienes son sorprendidos en su buena fe al adquirir bienes que ya fueron vendidos a otras personas con anterioridad (a veces muchas veces).

Por lo tanto, en la actualidad se produce una vuelta a las soluciones del pasado en cuanto a la intervención estatal, aunque en este caso la finalidad es diferente: No se busca el control del ciclo económico por parte del estado sino la protección de los terceros y las partes más débiles de la relación contractual, manteniendo el estado un papel tutelar, limitando la regla general de la autonomía de la voluntad en los casos en que de ella puedan derivarse resultados disvaliosos.

Aplicación del principio moderno de la intervención estatal: La intervención estatal se manifiesta principalmente mediante tres fenómenos legales: El dirigismo contractual, las nuevas formas del contrato y la posibilidad de revisión judicial de lo acordado.

1.- El dirigismo contractual: Tal como vimos anteriormente la posibilidad de dejar librado a la libre voluntad de las partes la celebración de ciertos contratos puede conllevar la existencia de abusos de la parte con mayor capacidad negocial. Es por ello que el estado, en los casos en que se encuentra involucrado el interés público, limita la capacidad de disposición de los contratantes. De esta forma, verbigracia, el contrato de trabajo se encuentra

legislado en forma detallada en lo que respecta al cumplimiento de las tareas, el cobro de los salarios, límites a los horarios, etc. Dichos límites tienen como base la protección de la parte más débil, por lo que cualquier convención que supere el mínimo impuesto es válida: No se trata de forzar un contenido sino de asegurar un *piso* de derechos que las partes, de así quererlo pueden superar.

2.- Las nuevas formas contractuales: La estructura clásica del contrato implicaba el libre acuerdo de voluntades celebrado entre particulares. Sin embargo, en la actualidad pueden encontrarse formas de perfeccionamiento del contrato donde uno de estos elementos se encuentra modificado.

Los contratos de adhesión son una forma contractual en la cual, las cláusulas se encuentran predispuestas por una de la partes, limitándose la otra a aceptar o rechazar la convención. Este tipo de contratos, que se encuentra ligado normalmente a economías de masas, conlleva una forma de interpretación particular, atento la incapacidad de una de las partes de modificarlo.

Los convenios colectivos modifican sustancialmente la concepción de contrato, en razón de su carácter público y su alcance más allá de los celebrantes. Esta forma de contrato nace con la representación gremial e implica una negociación de carácter general entre la organización sindical y el empresariado, convenio que una vez celebrado es aplicable a todas las relaciones laborales de la especialidad, hayan participado en la vida gremial o no.

Muchos autores han negado el carácter contractual al convenio colectivo, argumentando la ingerencia del derecho público lo aparta del concepto básico. En este sentido, debe tenerse en cuenta que en nuestro país, los convenios deben ser homologados por el ministerio de trabajo, circunstancia que lo aleja aún más del contrato en sentido clásico, habida cuenta que es la recepción estatal y no el acuerdo entre las partes lo que le da la fuerza obligatoria.

Los contratos forzosos son la forma más extrema de limitación. En esta hipótesis se elimina el consentimiento en forma casi total, dejando elementos accesorios del contrato a disposición del contratante. Así, las leyes de agio obligaron a los comerciantes a vender sus mercaderías a un precio prefijado, pudiendo elegirse sólo la persona del co contratante. En estos casos no

encontramos con excepciones basadas en el interés público, lo que permite al estado limitar, aunque sea provisionalmente, ciertas libertades económicas en pos del bien común.

III.- Clasificación de los contratos:

Es necesaria, antes proseguir con este tema, una ponderación previa respecto a las clasificaciones, toda vez que las mismas constituyen un modelo arbitrario de la realidad, dependiente casi en forma exclusiva de la voluntad del doctrinario. Sin embargo, si bien la elección de los caracteres definitorios de cada categoría pueden llegar a ser parciales, no por ello dejan de ser ciertos y nos permiten analizar la realidad contractual en forma organizada, aunque siempre teniendo en cuenta que se trata de modelos ideales, pudiendo un convenio determinado presentar características de mas de una de las categorías.

1.- Contratos Bilaterales y Unilaterales: Son convenios bilaterales aquellos en los cuales el acto jurídico genera obligaciones en ambas partes de la relación jurídica. En tal sentido, ambos contratantes se transforman a la vez en acreedor y deudor. Tal es el caso de la compraventa donde, por ejemplo, el vendedor es acreedor de la entrega de dinero, mientras que es deudor respecto de la entrega de la cosa. En cambio, en los unilaterales la relación sucede en un solo sentido, no existiendo esta interdependencia de prestaciones (vg. la donación)

Esta circunstancia tiene particular importancia al momento de analizar la excepción de incumplimiento y el pacto comisorio

2.- Contratos gratuitos y onerosos: En este caso el factor determinante es la existencia o no de contraprestaciones económicamente apreciables. Comúnmente se confunde esta categoría con la anterior, pero debe tenerse en cuenta que un contrato puede generar obligaciones a las partes que no sean apreciables en dinero, por lo que el contrato seguiría siendo bilateral pero no oneroso. Tal es el caso de los contratos de servicios de correo vía web, donde el usuario acepta obligaciones de abstención (vg el correo no puede ser usado para realizar spam) sin generar un intercambio económico con el sitio. Asimismo debe tenerse en cuenta que un contrato oneroso no siempre se expresa en sumas de dinero: basta que las contraprestaciones sean

apreciables económicamente para ser oneroso: Por ejemplo, en la permuta no existe intercambio de dinero, sin embargo es contrato oneroso toda vez que los bienes que se intercambian tienen un valor pecuniario.

3.- Contratos principales y accesorios: Son contratos principales aquellos que cuyo negocio jurídico se basta a sí mismo, sin necesidad de una convención adicional que les de sentido. En cambio, el contrato accesorio tiene un claro sentido instrumental, estando subordinado a la suerte de un principal. Tal es el caso de la fianza, contrato de garantía, cuya existencia depende de un convenio principal (vg. un contrato de alquiler), al que sirve de garantía.

4.- Contratos nominados e innominados: Cuando analizamos la evolución histórica del instituto, mencionamos que el principio de libertad contractual permitía a las partes fijar las cláusulas que estas entendían mejor se ajustaban al negocio que pretendían realizar. Sin embargo existen algunos contratos que, mas allá de esta potestad de las partes, se encuentran legislados en el ordenamiento, constituyendo estos la categoría de nominados.

Sin embargo la existencia de una regulación legal de un convenio no necesariamente limita la libertad de las partes al contratar. En este sentido es necesario analizar si las normas adoptadas tienen un sentido imperativo o meramente supletorio. Si estamos frente a una norma en sentido imperativo, las partes no pueden apartarse de lo dispuesto, mientras que las normas en sentido supletorio constituyen una regulación por defecto tendiente a suplir el silencio de la parte respecto de una cláusula usual del convenio: En tal sentido las partes tienen la facultad de convenir algo distinto a lo legislado, en cuyo caso la norma queda sin efecto.

IV.- Formación del contrato: Si definimos al contrato como un acuerdo de voluntades, es una consecuencia necesaria que para su formación será condición necesaria la concurrencia de por lo menos dos voluntades: Una primera que proponga el negocio jurídico y una segunda que lo acepte.

Podemos definir oferta como la proposición unilateral que una de las partes dirige a la otra para celebrar un contrato.

La regulación jurídica de la oferta en el código civil argentino (art. 1148) requiere la existencia de una propuesta que contenga todos los elementos del negocio jurídico, incluido a los sujetos a los que se encuentra dirigido: la

propuesta de contrato realizada a personas indeterminadas no constituye *per se* una oferta de contrato sino simplemente una invitación a ofertar a los hipotéticos destinatarios. Esta característica lo diferencia de la regulación establecida para los casos de contratos de consumo (vg. la publicidad de ofertas de un supermercado), los cuales constituyen una oferta obligatoria para quien la realiza. El elemento que separa ambas regulaciones es la relación de consumo, entendiendo a esta como aquella establecida entre un consumidor final de un producto o servicio determinado y un comerciante.

Respecto a la duración de la oferta, nuestro código establece que la misma es revocable en cualquier momento antes de la aceptación, excepto en los casos en que la parte expresamente haya limitado esta posibilidad al momento de la formulación. Excepcionalmente y en los casos en que la otra parte haya aceptado el contrato desconociendo la retractación y a tal fin se haya realizado gastos, esta tendrá derecho a resarcirlos pero no reclamar el cumplimiento del contrato.

Como contrapartida, la aceptación constituye el acto que consuma el acuerdo voluntades. Para que produzca su efecto propio es necesario que la misma sea lisa y llana, es decir que no modifique en modo alguno los términos de la oferta. Si ello no sucede no estaremos frente a una aceptación sino a una nueva oferta, la cual deberá ser aceptada por el anterior oferente.

Asimismo es necesaria que la aceptación sea realizada en tiempo oportuno, antes de la retractación del oferente. Esto tiene particular importancia en los contratos entre ausentes en los que el envío de aceptación y su recepción pueden estar separados entre sí por lapsos importantes. Por tanto, es necesario precisar que momento se entiende que la aceptación se realizó. En tal sentido la doctrina distingue cuatro soluciones legislativas posibles dependiendo si entendemos que la aceptación se realizó al momento de la declaración de aceptación, de su envío, de su recepción por parte del oferente o simplemente cuando este último tuvo conocimiento de la aceptación.

Como regla general y respecto a las relaciones regidas por el código civil, nuestro ordenamiento en el art. 1154 referido cuerpo legal define la cuestión estableciendo que el contrato se perfecciona al momento del envío de la aceptación. Sin embargo, y como excepción, el aceptante tiene derecho a

retractarse hasta tanto el oferente no haya tenido conocimiento de la primera declaración de voluntad (art. 1155).

V.- Elementos de los contratos

1.- Los sujetos: Toda relación jurídica implica necesariamente la existencia de sujetos de derecho, ya sea de existencia física o legal (sociedades, fundaciones, cooperativas o demás casos en que la ley otorga capacidad para ser titular de derechos y obligaciones). Respecto a una relación jurídica determinada podemos clasificar a los sujetos en:

La Partes: Las partes de una relación jurídica son aquellas que por si o por intermedio de un representante, se han obligado a cumplir cierta conducta o son titulares de un determinado derecho. Debe tenerse en cuenta que, en los casos de actos jurídicos, debe diferenciarse entre las partes y los firmantes u otorgantes del acto: Si bien en la mayoría de los casos ambas figuras coinciden en la misma persona, no necesariamente esto es así, como lo demuestra la figura del mandatario o representante ya sea legal o convencional.

Asimismo se considera partes a los sucesores universales de una persona fallecida. Esto es así porque para nuestro ordenamiento los sucesores de una persona fallecida continúan el lugar jurídico del causante. Sin embargo esta regla tiene excepciones:

1.- En los casos en que la obligación se hubiera realizado teniendo en cuenta las características personales del fallecido. Tal es el caso de la mayoría de las locaciones de obra, particular cuando el encargado de la obra contaba con cualidades particulares que eran definitorias del contrato (ej. El encargo de una obra a un pintor)

2.- En los casos que las partes al momento de contratar hayan definido que al muerte de una de ellas resuelve el contrato. En tal caso, los sucesores, si bien continúan la persona del causante, no esta obligados a prestación alguna ya que la misma dejó de existir con el fallecimiento.

3.- Los casos que se acepte la sucesión con el llamado beneficio de inventario. En tal caso los patrimonios del sucesores y el causante no se mezclan y se evita la confusión entre los mismos.

Los terceros: Desde un concepto amplio, puede decirse que un tercero es todo aquel que no es parte de una relación jurídica. Como principio general, los actos realizados por las partes no tiene efectos contra los terceros, salvo en el caso de transmisión derechos reales, los cuales son oponibles contra cualquier persona, haya o no participado en el acto de cuestión.

2.- La Causa:

La palabra causa tiene en el derecho dos acepciones diferentes: La primera refiere al hecho respecto del cual derivan las obligaciones, ya sean estas un hecho ilícito, la voluntad de las partes o simplemente la misma ley.

La segunda, y es la que nos interesa a los efectos de este apunte, significa el fin que las partes se propusieron al contratar. Según la doctrina más difundida, la causa es el fin inmediato y determinante que las partes han tenido al contratar, es la razón directa y concreta que las partes para la celebración del acto y atento ello, no puede ser ignorada por la contraparte.

Debe igualmente diferenciarse la causa de los meros motivos que las partes tuvieron al contratar. La primera son los fines inmediatos que una persona tuvo al celebrar un acto, la segunda, en cambio, son las motivaciones psicológicas que llevaron a las partes a hacerlo, las cuales no tienen efectos jurídicos inmediatos. Así, por ejemplo, en un contrato de compraventa de inmuebles, la causa es para el vendedor es el pago del precio, en cambio si los motivos puede ser la compra de un inmueble mas grande. Para el derecho, la satisfacción de este motivo ulterior carece de efectos: compre o no el segundo inmueble, la operación es válida.

La principal regulación de la causa, esta dada por los art. 500 y 502 del código civil. Ellos regulan los problemas derivados de la nulidad, o falsedad de la causa y sus efectos jurídicos. El art. 500 establece una presunción de existencia de la causa, aun en los casos en que la misma no este expresada al momento de la obligación. Esto obedece al hecho que por razones de seguridad jurídicas la validez de los negocios jurídicos se presume, siendo carga de quien plantea su nulidad la prueba de dichos extremos.

Sin embargo, puede ser la causa no existe, sea contraria a derecho o existiendo la misma sea falsa. En los dos primeros casos nos encontramos con

una relación jurídica sin causa, la cual debe reputarse nula (art. 502). Sin embargo, en el último caso, vemos que si bien la causa manifestada es falsa, puede ocultar otra válida. Tal es el caso de los actos simulados, donde las partes conscientemente crean una causa falsa, normalmente en perjuicio de sus acreedores u otro tercero, para ocultar otra causa real. En tales casos, el ordenamiento sostiene que si la causa real es válida, el acto simulado se mantiene. Esto es de particular importancia respecto a los terceros, toda vez que pueden oponer el acto a los simuladores, si así les conviene.

3.- El Objeto: El concepto de objeto refiere a la cosa o hechos sobre la cual recae la obligación contraída. En otros términos se trata de la prestación debida.

El objeto constituye un elemento fundamental de la relación jurídica, toda vez que no puede entenderse una relación obligacional donde nadie tenga obligación de nada. Sin embargo, no todo objeto es válido, debiendo cumplir lo normado por el art. 953 del Código Civil, el cual expresa:

El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de un acto jurídico o hechos que no sean imposibles, ilícitos contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conforme a esta disposición son nulos como si no tuviesen objeto.

En función del texto del artículo, vemos que el objeto debe cumplir con tres condiciones básicas:

1.- Debe ser Posible: Esta posibilidad física de realizar la prestación debe ser absoluta y no relativa al contratante. Por ejemplo, la obligación de construir una catedral o pintar un retrato puede resultar imposible para una persona no entrenada, pero la obligación sigue siendo válida entre las partes y su incumplimiento conlleva sanciones. En cambio, la prestación “saltar un edificio” es físicamente imposible y debe reputarse nula.

2.- Debe ser lícito: Todo objeto contrario al ordenamiento es nulo. Ello obedece a que el ordenamiento no puede otorgar validez a un acto que niega su vigencia, so pena de caer en un contrasentido lógico.

3.- Debe ser conforme a la moral y las buenas costumbres: Este concepto constituye un standard jurídico, el cual debe evaluarse en el caso concreto. Sin embargo, es conteste la jurisprudencia en calificar estas actividades como contrarias a la moral: La locación de inmuebles para casas de citas, los pactos de retroventa de automotores como garantía de un préstamo¹, los intereses usuarios.

Respecto a los efectos debe tenerse en cuenta si la prestación constituye una parte esencial de la convención o si, por ejemplo en los casos de pactos de retroventa o intereses, estamos frente a un accesorio. Normalmente en el primer caso se decreta la nulidad de toda la convención, mientras que en el segundo, simplemente afecta a la cláusula, dejando la relación jurídica vigente.

VI.- Efectos de los contratos. La excepción de incumplimiento y el pacto comisorio

a.- Principios Generales:

El principal efecto de la celebración de un contrato es que las partes quedan obligadas al cumplimiento de las cláusulas establecidas en el mismo. Es así que el artículo 1197 de código civil establece que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma.

El concepto de parte en el sentido jurídico del término debe diferenciarse de los signatarios del acto jurídico. Este último término se emplea para designar a las personas que aparecen celebrando el acto y manifestando su voluntad mediante la firma. Sin embargo no necesariamente ello los transforma en parte del contrato, toda vez que podemos estar frente a un representante de la parte como puede ser un mandatario o el representante legal de la misma.

Respecto de las personas que no revistan la condición de parte, existe un viejo principio jurídico que del derecho romano que establece que los

¹ Es particularmente común, en los casos de prestamos usurarios, la venta al prestamista de una automotor o inmueble como garantía con el agregado de una cláusula de devolución al deudor en caso de cumplimiento y de esta forma evitar la ejecución de la deuda o su discusión judicial. Esta convención accesoría es conocido como pacto de retroventa

contratos no obligan sino a las partes y no tienen efectos respecto de los terceros. Sin embargo debe tenerse en cuenta que esta regla tiene excepciones, a tal punto que algunos autores se preguntan si puede hablarse realmente de un principio general.

En primer lugar se considera que los sucesores universales de uno de los contratantes como parte. Esto es así, atento que para el derecho argentino el sucesor a título universal continúa la persona del fallecido, adquiriendo todos los derechos y obligaciones de este último. Sin embargo, esta ficción legal se encuentra en la actualidad limitado por el llamado beneficio de inventario, instituto del derecho sucesorio que limita la responsabilidad del heredero respecto de las deudas del causante al patrimonio heredado. De esta forma, el heredero se transforma en un tercero por lo menos respecto los bienes de su propio activo, los cuales no pueden ser ejecutados por los acreedores del causante.

De la misma manera, debe tenerse en cuenta que las partes pueden haber previsto la disolución de las obligaciones en caso de muerte, en cuyo caso tampoco estaríamos frente a una continuación de las mismas. Por último, es necesario señalar que en los casos en que las convenciones se hayan realizado teniendo en cuenta las circunstancias personales de los contratantes, las mismas no se trasladan a sus herederos.

En segundo lugar, es posible que las partes hayan convenido cláusulas a favor de terceros. Tal es el caso, por ejemplo de las indemnizaciones derivadas de los seguros de vida, la cual es pagada al beneficiario de la póliza y no al contratante o sus herederos. En tal caso nos encontramos ante varias relaciones jurídicas diferentes: Una entre los contratantes, una segunda que se establece entre el estipulante y el beneficiario y una tercera, de carácter directo, entre el beneficiario y el obligado al pago. Debe tenerse en cuenta que en esta hipótesis el beneficiario no participó en momento alguno en la negociación o redacción del acuerdo.

b.- Límites a la obligatoriedad de los contratos: Tal como veníamos diciendo al hablar de evolución histórica, la autonomía de la voluntad como fundamento de la obligatoriedad de los contratos encuentra su límite en la función social del instituto, por ende la capacidad de obligarse de los

contratantes tiene por contrapartida un límite establecido. En este sentido, los contratos carecerán de fuerza obligatoria:

- 1.- Si son contrarios a leyes de orden público: En estos casos englobamos asimismo las cláusulas imperativas de los contratos nominados.
- 2.- Si son contrarias al moral. El art. 953 del código civil establece que las convenciones no pueden ser contrarias a la moral. En tal caso estamos frente a un estándar jurídico que ha ido evolucionando con el correr del tiempo, englobando no solo cuestiones de índole sexual (vg. contratos sobre casas de tolerancia) sino cláusulas de contenido económico, las cuales implicaban un aprovechamiento del estado de necesidad de uno de los contratantes. Tal es el caso de las cláusulas usuarias o penales exorbitantes.
- 3.- Por último, debe tenerse en cuenta que el 1198 del Cod. Civil establece que los contratos deben ejecutarse y celebrarse de acuerdo a las reglas de la buena fe. Este principio conlleva necesariamente la limitación de las partes quienes no pueden lucrar con la inexperiencia o necesidad de la otra parte, so pena de violar este principio. En el mismo sentido, debe tenerse en cuenta que en un aspecto dinámico las partes pueden apartarse de lo establecido en la convención cuando circunstancias sobrevinientes modifiquen en modo sustancial la ecuación económica del arreglo.

c.- La excepción de incumplimiento: La excepción de incumplimiento implica la potestad jurídica de una de las partes a negarse a cumplir el requerimiento de la otra, en los casos en que esta se encuentre en mora (no haya cumplido) las obligaciones que, derivadas del contrato tenía a su cargo

El origen de la excepción se remota al derecho romano, ordenamiento que otorgaba a los demandados una excepción de carácter procesal destinada a evitar la prosecución de un juicio de incumplimiento de contrato en los casos en que la demandante no haya cumplido las obligaciones a su cargo.

En la actualidad esta excepción encuentra su base en la existencia de una relación de reciprocidad entre las partes de un contrato bilateral: Al existir un equilibrio entre las prestaciones, es necesario que la parte que pretenda la ejecución de las obligaciones que le son debidas no puede estar constituido en mora. Por lo tanto los requisitos para la procedencia de la excepción de incumplimiento son las siguientes:

- 1.- Que se trate de un contrato bilateral

2.- Que las obligaciones de sean exigibles: En este sentido si las mismas se encuentran sujetas a plazo o condición y este no se ha cumplido, no es posible plantear su incumplimiento toda vez que en realidad todavía no es obligatorio el pago.

3.- Que la requirente haya dejado de cumplir total o parcialmente sus obligaciones: En este caso no es posible hacer distingos entre una y otra, sin embargo es necesario puntualizar que debe guardarse un equilibrio entre el incumplimiento y la obligación a excepcionar, de forma tal de evitar los abusos derivados de plantear el instituto en los casos de incumplimientos mínimos o de poca importancia.

d.- El pacto comisorio: Se llama pacto comisorio a la convención por la cual las partes acuerdan resolver el contrato en caso de incumplimiento de una de ellas, abriendo por lo tanto la posibilidad de solicitar directamente daños y perjuicios.

Tradicionalmente, la procedencia del pacto comisorio estaba sujeta a la expresa manifestación de las partes en tal sentido. Así, en el derecho romano el principio era que las partes solo podía solicitar el cumplimiento del contrato, para resolver el acuerdo era necesario asimismo la existencia de una cláusula expresa en tal sentido.

Similar era la inteligencia del código civil argentino en su art. 1204, hasta la reforma del decreto ley 17711/68. El nuevo art. 1204 prevé dos situaciones que legisla separadamente: Que el pacto comisorio haya sido expresamente establecido y los casos en que se omitió, en cuyo hipótesis se considera que el mismo se encuentra incluido en forma tácita.

En el pacto comisorio tácito, ocurrido el incumplimiento, la otra parte debe intimar al cumplimiento de la obligación por un plazo no inferior a los quince días, con más los daños y perjuicios derivados del incumplimiento, plazo que vencido habilita a resolver sin más las obligaciones emergentes del contrato, con derecho al resarcimiento de daños y perjuicios.

Debe tenerse en cuenta que el plazo de quince días puede acortarse en los casos en que se haya pactado un plazo diferente (vg. si se determinó que todos los plazos de un contrato serán de 72 horas desde recibida la notificación).

En cambio el pacto comisorio expreso no es necesaria la intimación previa para resolver el mismo: El tercer párrafo del art. 1204 establece que el mismo producirá efectos desde la manifestación de la parte comunicada en forma fehaciente.

Respecto a la forma de comunicación, si bien el código no establece formas solemnes debemos tener en cuenta que toda vez que es necesaria fecha cierta tanto para establecer el plazo de intimación como la propia resolución del contrato, la comunicación debe hacerse en forma fehaciente, utilizándose en la práctica una carta documento.

Respecto de los efectos del pacto, el contrato queda sin efectos retroactivamente, debiendo las partes devolverse lo que hubieran recibido en función del mismo, teniendo asimismo la parte que ha cumplido derecho a ser resarcida por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento.

Asimismo es necesario analizar en los casos en que ambas partes ya incurrido en culpa. En tal caso, el juez puede declarar el contrato resuelto pero no otorgar daños y perjuicios a ninguna de las partes. Sin embargo, es posible que la culpa de las partes no sea equivalentes (vg. que una sea sólo un incumplimiento parcial contra otro total) en cuyo caso el juez puede establecer una indemnización reducida en beneficio de una de ellas.

Por último debe tenerse en cuenta que la declaración de resolución de contrato mediante el pacto comisorio impide exigir el cumplimiento del contrato, toda vez que el mismo ya se encuentra resuelto.

CONTRATOS INFORMATICOS

I

1.- Introducción: Concepto y caracteres del contrato informático

La irrupción de nuevas tecnologías tendientes al tratamiento, almacenamiento y recupero de la información, dieron lugar a figuras contractuales diversas que pronto adquirieron características propias, las cuales generaron nuevos institutos jurídicos y principios privativos de dichos negocios jurídicos.

El concepto de contrato informático en nuestra doctrina se relaciona con todos aquellos negocios jurídicos que tienen por objeto los sistemas destinados a la gestión organizada de información. Mosset Iturraspe¹ define al instituto como “... *la operación jurídica mediante la cual se crean, modifican, transmiten o extinguen relaciones obligacionales sobre bienes y/o servicios informáticos. Estos bienes se integran generalmente en un sistema, que el conjunto de elementos materiales o inmateriales, ordenados e independientes, vinculados con un objetivo común*”.

Para Bergel los aspectos singulares de la contratación informática son los siguientes: a) Acentuación de la distancia entre el proveedor y el cliente b) Diferencias en los objetivos de las partes al contratar c) Dificultades en la individualización del objeto contractual d) Parámetros relativos al incumplimiento de la prestación e) problemas suscitados con la redacción f) Predominio de contratos mixtos y con cláusulas predisuestas².

El problema de la definición del objeto: El concepto de sistema

La definición de Mosset Iturraspe, delata la existencia de una particularidad de los contratos informáticos, como es la interrelación de los elementos disímiles que conforman el objeto del negocio en un sistema ordenado destinado a la concreción de un bien concreto. Esta característica de sistema, tal como fue receptado en nuestra jurisprudencia en el caso “*Sisteco, Sistemas de computación S.A. c/ Sujoy Sergio*”³, plantea una nueva característica de los contratos de provisión de servicios informáticos, como es la diferenciación en la causa final de los contratantes.

Debe tenerse en cuenta que a diferencia de, verbigracia, una compraventa tradicional la intención de el usuario y el suministrador de un servicio informático se aproximan al negocio jurídico con intenciones opuesta, toda vez que mientras que el primero tiene la intención de obtener un resultado determinado, el segundo solamente se compromete a la entrega de un universo de bienes con determinadas especificaciones técnicas.

Dicho de otro modo, mientras que el usuario intenta obtener una funcionalidad determinada, el proveedor busca la comercialización de un conjunto de bienes materiales e inmateriales. Se podría argumentar que esta característica se repite en la mayoría de los contratos de consumo, pero con una salvedad: Un ordenador no mantiene una funcionalidad ontológica sino que depende de su configuración. A diferencia de, verbigracia, un televisor, un sistema informático no cumple una función específica sino que depende del hardware que lo constituya, los programas que se encuentren instalados, la conectividad con que cuente. Pensemos simplemente en una pc hogareña y veremos que las configuraciones posibles son múltiples: ¿Vamos

¹ Mosset Iturraspe, “*La Excepción de Incumplimiento en el contrato informático y la condena condicional*”, La Ley, T 1991- A, Pag. 402 y siguientes

² Bergel Salvador Darío, Notas sobre la contratación informática, RDPC, N° 3, pags. 185 y sigs.

³ La Ley, T 1987 -A, Sección Jurisprudencia, páginas 136 y siguientes.

a realizar tratamiento de imágenes? Entonces necesitaremos más memoria, buena impresora y el software adecuado (photoshop, autocad, etc). ¿O simplemente navegaremos por Internet y consultaremos el correo? ¿Tiene sentido la adquisición de una placa de video de alta gama si no pensamos utilizar los últimos juegos salidos al mercado?

El concepto de sistema permite unificar los componentes informáticos en una universalidad definida por su función. Sistema será, entonces, el conjunto de bienes que permitan realizar la tarea específica solicitada por el usuario, de forma tal que la mera entrega de los componentes no satisface la obligación del proveedor sino que se hace necesaria su puesta en funcionamiento y la satisfacción de la necesidad del usuario

A esto último debe sumársele notoria diferencia en el conocimiento que sobre el objeto de la contratación poseen las partes. Tal como reiteradamente lo han hecho notar la doctrina y jurisprudencia⁴, el usuario no posee el conocimiento técnico necesario para una toma de decisión fundada, sino que debe confiar en la información suministrada por el proveedor, quien ejerce, *de facto*, un monopolio sobre la información material y técnica que dará lugar al negocio jurídico.

Frente a esta realidad, es necesario encontrar una solución jurídica que permita no solo compatibilizar los intereses dicotómicos de las partes sino eliminar la brecha tecnológica que las separa, volviendo a establecer la igualdad negocial.

La obligación de información: Concepto

En los contratos informáticos, tal como se ha dicho, tienen por objeto principal una universalidad de bienes materiales e inmateriales compleja conocida como **sistema**, la cual tiene un componente teleológico, que le sirve de definición y sustento.

Atento a ello, un sistema informático solo es útil cuando sus objetivos han sido definidos claramente por parte del usuario, así como cuales son los impactos que sobre la organización y la empresa se han de producir. Como contrapartida, es obligación del proveedor de los bienes el asesoramiento y consejo respecto a la tecnología a incorporar a los efectos de que el sistema efectivamente adoptado guarde relación con los fines requeridos por el usuario.

Todo ello es en realidad una derivación de la buena fe con que las partes deben concurrir al acto contractual, que se traduce en un deber de colaboración entre ambos a los efectos de definir los componentes y extremos del sistema.

El Deber de Asesoramiento y Consejo.

Concepto y Fundamentos: El deber de asesoramiento y consejo en cabeza del proveedor de sistemas de información se relaciona con la determinación del objeto de contrato, así como el en la concordancia entre los fines pretendidos por el usuario y la prestación final del proveedor.

Atento, tal como se ha manifestado anteriormente, la existencia de una disparidad de conocimiento tecnológico entre el proveedor y el usuario, es obligación

⁴ En particular ver Almark, Daniel “*Contratos Informáticos. El contrato de mantenimiento*” en Rev. La Ley, T 1986-B, pag. 719, Messina de Estrella Gutierrez “*Asunción de las realidades tecnológicas -informática - por el proyecto de unificación civil y comercial*”, La Ley T 1988- A, Pag 734. y jurisprudencialmente, *Sistex S.A. c/Oliva S.A. Valerio*”, La Ley, T 1991-A, voto de la doctora Kemelmajer de Carlucci

del primero aconsejar y ayudar a la determinación de las características del sistema de forma tal que se adecuen a los objetivos propuestos por este último.

Ya la Corte de Casación Francesa en el año 1971, en autos “*Soc. Bourroughs vs. Société A del Prete y Locafrance*” señaló la obligación del usuario de responder en los casos de que el sistema desarrollado no cumpla cabalmente con los objetivos solicitados por el usuario, siendo indiferente a los efectos de definir la responsabilidad si los distintos componentes del mismo funcionaban o no correctamente.⁵

Cabe en cabeza del proveedor de servicios, entonces, la necesidad de informar en forma cierta y objetiva las características del objeto del contrato, de forma tal que evite la contratación de sistemas insuficientes a los efectos de la tarea a realizar, así como aquellos cuyo costo y prestaciones superen ampliamente las necesidades, generando un costo injustificado en cabeza del usuario.

Nuestra Ley de Defensa del Consumidor en el artículo 4º impone a los empresarios el deber de suministrar a los consumidores, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada y suficiente sobre las características esenciales de los productos o servicios comercializados. Esto conlleva una relevancia práctica que radica, principalmente, en la influencia que la información retaceada o falseada ejerce sobre el consentimiento, toda vez que la misma ley prevé la posibilidad de sanciones de nulidad ante la infracción a dichos principios.

En realidad, tanto la obligación de consejo como el deber de información al consumidor, no son mas que la aplicación a distintos campos del derecho de principio de la buena fe contractual consagrado en el artículo 1198, que sostiene que en materia de contratos, ellos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo a lo que las partes verosimilmente entendieron o pudieron entender.

Siguiendo la terminología de Spota, debe distinguirse entre la buena fe-creencia de la buena fe-lealtad, siendo esta última el deber de actuar con probidad, como lo haría una persona honorable y correcta, obrando con cuidado y previsión.

Por ende, y aplicando dichos principios al caso concreto, la partes deben recíprocamente, consideración y lealtad en punto a sus mutuas esferas de interés, evitándose errores, a cuyo efecto es regla esencial la del *clare loqui*, y la obligación de evitar caer en reticencias que, de haber sido manifestadas, habrían obstado a la concreción del contrato o por lo menos hubieran impulsado su modificación.

Dicho requisito de buena fe se traduce en los contratos informáticos en la obligación del profesional, quien detenta el monopolio de la información técnica, de no abusar de su posición dominante, debiendo traducir fielmente las necesidades del cliente en términos de la tecnología a aplicar. Debe tenerse en cuenta que la existencia de o no de diferencias económicas es indiferente a los efectos de la presente obligación : El desequilibrio negocial de las partes se produce atento a la presencia de una parte lega en la materia y otra experta, sin importar, prima facie, las diferencias económicas de las partes.

Contenido : El contenido del deber de consejo se circunscribe a lo que sea relevante y suficiente, con miras a la toma de una decisión. De lo anteriormente dicho, se desprende que la obligación de consejo mantiene una doble faz : Una activa, en tanto es obligación del proveedor la determinación de las características técnicas esenciales del contrato, así como la explicitación de los riesgos a asumir

⁵ En el mismo sentido, “*Société Flammarion y Cia vs Société IBM France*” de 1972, ambos citados en Bergel, Salvador Dario, “*Informática y Responsabilidad Civil*”, Colección Informática y Derecho, Tomo 2, Pags 157 y siguientes.

por el usuario, y otra pasiva o de abstención, al imponer en cabeza de este la obligación de no ser reticente u ocultar información pertinente al contrato.

Si bien dicha obligación no se encuentra legislada en nuestro derecho, debe tenerse en cuenta lo normado por la Ley de Defensa del Consumidor cuando exige que la información suministrada a los consumidores y usuarios, sea veraz detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de la prestación.

La veracidad de la información esta referida a la sinceridad con que debe ser emitida: La información no es veraz cuando su contenido es engañoso, particularmente cuando silencia datos esenciales, creando en el destinatario expectativas que no son factibles de ser satisfechas o cuando induce a error por omisión de circunstancias relativas a la prestación.

Que la información sea detallada, implica la necesidad de que el consumidor tenga la posibilidad de informarse acerca de las auténticas características de los productos y servicios que le son ofrecidos. Debe tenerse en cuenta en lo relativo las contrataciones informáticas que dicha información debe ser relacionada con las necesidades expresadas por el usuario: No es la mera enunciación de las características técnicas de los equipos y software a utilizar, descripción que en la mayoría de los casos se encuentra más allá de la posibilidad de comprensión del operador final, sino básicamente como estos posibilitan la concreción de los objetivos propuestos en el estudio de necesidades del usuario.

La eficacia de la información está referida a la potencialidad disuasoria, es decir la capacidad de generar una decisión en cabeza del usuario, creando una relación de causalidad entre la emisión de la información y la celebración del contrato. Demás esta decir que dicha información debe cumplir con los requisitos de veracidad y autenticidad anteriormente analizados.

La suficiencia sobre las características esenciales de las prestaciones o servicios ofrecidos alude a la necesidad de que los detalles, descripciones y especificaciones sean aptos para habilitar al consumidor a tomar una decisión reflexiva con conocimiento de causa. La ausencia de dicho requisito implica una maniobra dolosa de ocultamiento de información pertinente que podría generar dolo en la voluntad del contratante.

La importancia de la cuestión radica fundamentalmente en los casos en los que la falta de información suficiente determinó el consentimiento, imponiendo la contratación de servicios que de otra forma no hubieran sido celebrados.

La jurisprudencia francesa en varias oportunidades ha tenido ocasión de analizar el tema. En el caso "*Olivetti e. Karpathios*", entre otros, la Cámara de Casación francesa revocó la contratación por entender que el sistema proveniente por la firma Olivetti consistente en tres programas de facturación, stock, y registro de pagos no resultaban compatibles entre sí y por ende la empresa había incumplido su deber de consejo, atento que el sistema entregado no cumplía los objetivos propuestos por la parte usuaria⁶.

Debe tenerse en cuenta que nuevamente este fallo pone de manifiesto la relación existente entre las necesidades del cliente y la obligación de aconsejar por parte del proveedor de servicios informáticos. Es la ausencia de correlación entre el objetivo propuesto y el sistema entregado compromete la responsabilidad del profesional interviniente. Es obligación de este último no solo la provisión del material informático sino que debe necesariamente convertirse en interprete de la voluntad del usuario traduciéndola en un sistema capaz de satisfacerla.

⁶ En el mismo sentido "*Deslandes et Thurler c. Burroughs*", y "*Faberge c. Chauvin*" ambos citados en Altmark, Daniel Ricardo y Molina Quiroga, Horacio, "*Contratos Informáticos. La Etapa Precontractual*."

Naturaleza Jurídica: Cabe preguntarse asimismo sobre la naturaleza jurídica de la obligación. En el caso de la presente, como obligación de hacer, es menester dilucidar si la misma constituye una obligación de resultado o de medio, según se haya prometido un cambio en el estado de hechos determinado o tan solo la puesta disposición del acreedor de los medios tendientes a la concreción de dicho fin.

Dicha cuestión tiene, mayor importancia en lo referente a la prueba, atento al hecho que si entendemos a esta obligación como de resultado, la mera demostración de inexistencia de adecuación, daría lugar a la condena.

En general y atento a la disparidad de conocimientos informáticos anteriormente analizada, como a la ausencia de injerencia por parte del usuario en la elaboración de la oferta, el autor de la presente se inclina a considerar a la misma como de resultado, atento que atento a la divergencia debe presumirse que la misma fue responsabilidad del proveedor.

Sin embargo, dicha obligación termina en la elaboración del consejo, por lo que debe eximirse al proveedor de la responsabilidad de decisión final del usuario : El contenido de la obligación de consejo se satisface con la expresión de una información veraz, eficiente, detallada y suficiente del sistema propuesto a los efectos de la toma de la decisión, siendo independiente de la decisión final de usuario : Lo que ampara ordenamiento es el derecho a tomar decisiones con conocimiento de causa y no el derecho a tomar malas decisiones.

De igual manera la existencia de diferencias entre lo aconsejado y lo finalmente ejecutado, podrán dar lugar a responsabilidades contractuales por falta de cumplimiento de lo pactado o vicios redhibitorios pero no por la obligación de consejo, toda vez que la misma se agota en la emisión de la oferta o subsiguientemente con cada una de las opiniones formuladas por el proveedor a lo largo del contrato.

Por todo ello, es conveniente, en particular en la etapa precontractual, la elaboración de actas de intención, minutas u ofertas por escrito, donde se deje asentado la oferta realizada por la parte profesional, a los efectos de poder, en caso de conflicto, dilucidar las respectivas responsabilidades

La jurisprudencia francesa ha evolucionado considerando en una primera etapa a la obligación como de resultado, para posteriormente considerar a la misma como simplemente de medios. Así en 1971, señaló que el proveedor podía ser responsabilizado por el hecho de que el sistema no era adecuado aunque materialmente el material -material y software- estuviera en buenas condiciones funcionamiento⁷. Sin embargo, posteriormente, el mismo tribunal sostuvo in re “*Société Flammarion y Cia. vs. Société I.B.M. France*” que el operador no puede ser responsabilizado por el éxito total de la operación de informatización, toda vez que el resultado depende de la calidad misma del material y las condiciones en que el material ha sido implementado⁸.

El autor de la presente disiente con la interpretación de la Corte de Casación, atento que la misma relaciona la obligación de consejo con el resultado final de la informatización. Debe tenerse en cuenta que la misma es una obligación de información y satisface con la correcta manifestación al usuario: si la responsabilidad se deriva de un error en la implementación de lo aconsejado o de un riesgo previsto y aceptado por las partes, estaríamos en un campo ajeno al deber de consejo. Mismo es el caso en que estemos frente a una situación de fuerza mayor, en la

⁷ In re “*Soc. Bourroughs vs Société A del Prete y Locafrance*”, de 1971

⁸ “*Société Flammarion y Cia. vs. Société I.B.M. France*” de fecha 12/2/72, citado en Bergel, Salvador Dario, Op. Cit nota 4

responsabilidad de las partes se excusa. Si, en cambio, la deficiencia se deriva en la ausencia de previsión de los riesgos de la cosa, indudablemente la información ha sido deficiente y por ende el proveedor debe responder. No debemos olvidar siempre que se produce un daño, existe un responsable. Si sostenemos que los riesgos inherentes a la cosa no deben ser tenidos en cuenta al formular el consejo, estaríamos perjudicando a la parte cuya falta de formación técnica le ha impedido prever el problema, en beneficio de la parte profesional, de quien se espera la mayor diligencia.

El deber de colaboración. La elaboración de Cuadro de Necesidades. El equilibrio en las contraprestaciones:

La existencia de los anteriormente referidos deberes por parte del proveedor del servicio no significan dejar al usuario en una situación pasiva. Tal como se expresare al definir la obligación de informar, recaen en cabeza del usuario ciertos deberes de diligencia a los efectos la conclusión fructífera de la relación contractual.

Esto es particularmente importante durante la etapa precontractual atento que, en virtud del principio de la buena fe, es cuando ambas parte deben entablar un dialogo a los efectos de definir cuáles son los elementos necesarios de satisfacción.

Es el usuario quien debe definir cuales son los elementos a informatizar así como las situaciones de hecho y características organizacionales sobre los cuales dicha informatización producirá.

La jurisprudencia tradicionalmente ha puesto en cabeza del futuro utilizador la carga del análisis a fin de conocer o hacer conocer sus objetivos exactos y sus necesidades correspondientes. Es este quien debe proveerse de la información necesaria sobre las facetas de su organización, así como la carga y condiciones en que la tarea a informatizarse debe llevarse a cabo. Una falta en este análisis puede llevar a plantear necesidades que no se condicen con la realidad y la formulación de un sistema deficiente o sobredimensionado, con los consiguientes perjuicios para sí. Cabe preguntarse cual es la responsabilidad que le incumbe a la parte usuaria y por defecto a la proveedora.

Resulta interesante a este respecto analizar la postura de la jurisprudencia francesa al respecto de la cuestión. Hasta 1979, los tribunales galos habían sostenido la exclusiva responsabilidad del cliente en cuanto a la formulación de su cuadro de necesidades. Sin embargo en dicho año, la corte de París sostuvo que si bien es obligación del cliente la formulación de sus necesidades, es obligación del proveedor el ayudar a la formulación de las mismas corrigiendo los errores que según su conocimiento las mismas pudieran tener. En realidad, se trata de un proceso de colaboración en el cual cada parte debe cumplir un rol: el usuario debe expresar los objetivos y problemas que el sistema debe tender a solucionar, al mismo tiempo es el proveedor quien debe encauzar las mismas, traduciéndolas en las especificaciones técnicas que constituyen su oferta.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la obligación del usuario de elaborar su cuadro de necesidades debe cumplir con el estándar que el código establece como un buen hombre de negocios y, por ende, si las circunstancias lo aconsejan, debe concurrir a un asesor externo a los efectos de poder identificar y definir sus necesidades⁹. Cabe preguntarse entonces si existen variaciones en función de la presencia de dichos asesores e incluso si existe eximientes de

⁹

Así lo ha entendido el Tribunal de París in re “*Chabeneau vs. Société Olympia France S.A.*”. de 4/8/76

responsabilidad en el caso de que el usuario sea por si mismo un experto o detente suficientes conocimientos en el campo de la informática.

Debe tenerse en cuenta que en dichos casos la diferencia analizada entre lego y profesional se disipa, al encontrarse frente a una situación en la que los niveles de conocimiento se equilibran, permitiendo la recomposición *de facto* de la igualdad negocial.

De esta manera *in re* “*Ste. Sopresur N.C.R. vs Sté Groupe Lebrun*”¹⁰, la cámara 5º de París resolvió que el proveedor limitaba su responsabilidad, si el cliente habría contratado los servicios de una firma consultora especializada en el tema, quien había elaborado el pliego de condiciones sobre el cual se realizó el contrato.

En dicho caso la responsabilidad del proveedor se limita al cumplimiento del pliego de condiciones como asimismo a proveer la información solicitada por la consultora. En dichos caso en opinión del autor de la presente, nos encontraríamos frente a un caso de transferencia de la responsabilidad desde el proveedor hacia la consultora quien debe hacerse responsable frente al usuario a título de incumplimiento contractual por los defectos en la confección de los pliegos.

En referencia de un usuario entrenado en la utilización de la tecnología, no parece procedente imputar al proveedor con la obligación de consejo: nuevamente nos encontramos frente a un usuario calificado, capaz de entender por si mismo los términos de la oferta.

La jurisprudencia francesa ha entendido como un usuario calificado a aquellas personas que cuentan en su organización con un departamento de informática o en aquellos casos en que la negociación no se ha realizado sobre materiales informáticos de primera generación. En dichos supuestos, se ha sostenido, la obligación de consejo del proveedor se halla reducida.

Por último, es menester definir la naturaleza jurídica de el deber de información de las necesidades por parte del usuario. Al respecto cabe preguntarse si nos encontramos frente una verdadera obligación o simplemente frente a una carga. El concepto de carga, que nace del derecho procesal, es definido por el maestro Couture como “*un imperativo en el propio interés*”¹¹. La carga, a diferencia de una obligación, constituye un débito sin acreedor: La ausencia o incumplimiento de la misma no generan perjuicios o beneficios sino para la persona a cargo de la cual de encuentra el cumplimiento y por ende carece de sujeto que puede exigir su cumplimiento forzoso.

Sobre el particular cabe preguntarse si es posible por parte del proveedor exigir la corrección o entrega de un cuadro de necesidades al que considera falso o deficiente. Más allá de plantear la situación, dejando a salvo su responsabilidad, no parece existir daño en el incumplimiento: El resultado final de dicho proceso no perjudicaría a nadie más que al usuario, quien se encontraría frente a un sistema inadecuado.

La posibilidad de un inicio de acciones a los efectos del cobro de lo pactado, en los casos que existiera negativa de abonarlo por parte del usuario, no convierte al deber de informar en una obligación, toda vez que no existe identidad de objeto: El fin del proceso no sería la corrección del cuadro de necesidades sino simplemente el cobro de un trabajo realizado. La improcedencia de una excepción de incumplimiento por parte del usuario, en este caso, no hace sino reafirmar el

¹⁰ “*Ste. Sopresur N.C.R. vs Sté Groupe Lebrun*” citado en Bergel, Salvador Dario, *Op. Cit* nota 4

¹¹ Eduardo Couture, “Fundamentos del derecho procesal civil”, Editorial IB de F, Bs As, 1998

carácter de carga de la presente, generando un perjuicio en su contra merced a su propio incumplimiento.

Por todo ello, el autor de la presente sostiene el carácter de carga del deber de informar en cabeza del usuario.

La Aplicación del principio de sistema y deber de consejo a nuestro derecho: Los casos “Sisteco S.A. c/ Sujoy” y “Sistex S.A. c/Oliva S.A.”

Si bien no existe en el país una legislación regulatoria del contrato informático, los institutos referidos en la misma han sido receptados en la jurisprudencia nacional en dos casos “*Sisteco S.A. c/ Sujoy*” fallado por la Cámara Nacional en lo comercial, Sala E en junio de 1986 y “*Sistex S.A. c/Oliva S.A.*” sentenciado por la suprema Corte de Mendoza Sala I en febrero de 1990.

En el primero de los fallos, la actora Sisteco S.A. demanda por cobro de pesos sobre el saldo impago de una compraventa de un equipo de computación celebrada en el año 1979. El demandado reconoció la existencia del contrato, oponiendo a la acción la excepción de incumplimiento por entender que la contraparte no había cumplido con la instalación y puesta en funcionamiento del equipo.

El caso presenta interés toda vez que recepta por primera vez el concepto de sistema como la correlación entre un universo material y un objetivo fijado de antemano. La cámara al fallar a favor del demandado, sostiene la procedencia de la excepción de incumplimiento por entender que “... *a los efectos de la aceptación del sistema adquirido y de la asunción de la obligación de pago, es necesaria la operación conforme del conjunto de elementos componentes del sistema y su utilidad y adecuación a los fines previstos*”¹²

De esta manera, la sentenciante modifica el concepto de entrega en los casos de equipos informáticos, requiriendo por parte de la proveedora no solo la mera transmisión de los bienes sino que los mismos cumplan con los objetivos previstos al momento de adquirirlos.

El segundo de los casos bajo análisis plantea los fundamentos del deber de consejo como asimismo marca pautas interpretatorias en relación a los supuestos de oscuridad.

En el extenso fallo de la doctora Kemelmajer de Carlucci analiza la existencia del desequilibrio técnico entre las partes. Al respecto sostiene que “*Aunque el adquirente o el usuario sea una persona avezada en el ramo comercial de su actividad, generalmente carece de suficientes conocimientos y experiencia en materia de utilización de equipos de elaboración electrónica de datos. En otros términos hay entre los contratantes una brecha tecnológica que se advierte en la tecnología empleada, poco comprensible para el hombre medio*”

Asimismo la sentenciante pone de manifiesto la existencia de una disparidad de objetivos entre las partes cuando sostiene que “*El usuario y el suministrados del servicio se aproximan a la negociación con actitudes radicalmente diferentes: El primero espera del contrato un cierto resultado funcional, el segundo en cambio, tiende a prometer una simple correspondencia del sistema de determinadas características y especificaciones técnicas*”

Finalmente el fallo extrae de esta situación de hecho la existencia de la obligación de información y consejo en cabeza del proveedor del servicio informático

¹² CNCom, Sala E, 26/6/86 “*Sisteco Sistemas de Computación S.A. c/Sujoy Sergio*”, LL 1987-A-137, ED 122-437.

en el considerando VII punto 4 in fine cuando expresa “... *Esta situación también se extrae la obligación de información y consejo que recae sobre el proveedor del servicio*”

Como puede observarse si bien la obligación de consejo no se haya legislado específicamente, es claro que existen elementos suficientes en ambos fallos como para realizar una construcción jurisprudencial del tema.

Los límites de la obligación de consejo:

Si admitimos entonces la existencia de una obligación de consejo y acordamos en su contenido, debemos por último definir cuales son los límites que dicha obligación mantiene. Al respecto y a los efectos de su estudio, debemos dividirlos en temporales y materiales.

En el aspecto temporal la obligación de consejo debe extenderse por toda la vida contractual: El fundamento de tal afirmación se encuentra en el art. 1198 de nuestro código civil: si sostenemos que los contratos deben necesariamente cumplirse e interpretarse de buena fe y asimismo admitimos que la obligación de consejo encuentra su fundamento en la buena fe lealtad debida entre las partes, es una conclusión lógica que, atento a su carácter derivad, la misma se extiende mientras exista este deber de comportamiento entre las partes.

Sin embargo, el contenido de la misma varía según estemos hablando de la etapa precontractual o durante la ejecución del contrato. En la etapa precontractual, el deber de consejo se refiere básicamente a la elección de los componentes del sistema y los materiales. En la etapa contractual, en cambio, dicha obligación se encuentra referida a la formación del personal, la reorganización del servicio y –en su caso- a la gestión de los componentes del sistema.

En referencia a los aspectos materiales del sistema, es necesario definir cuales son los campos específicos sobre los cuales debe versar el consejo. Frente a esto, es necesario realizar algunas precisiones.

En primer lugar, la obligación de consejo encuentra su fundamento en la diferencia de conocimiento técnico entre las partes contratantes. Ya hemos visto que, en los casos que esta diferenciación desaparece, ya sea por presencia de un tercero consultor o por las propias características del usuario, la obligación de consejo se encuentra limitada o desaparece¹³

En segundo lugar, el contenido de la carga encuentra su concreción en el carácter técnico del proveedor, atento a su función de traductor de las necesidades del cliente en un sistema que de cumplimiento a las mismas. La pretensión de ampliar la obligación de consejo a elementos fuera del área técnica violenta dicha función, confundiendo los papeles del proveedor y usuario, en referencia a la redacción de las necesidades y situaciones de hecho en que estas se desarrollan.

En tercer lugar, una ampliación violenta el principio de la buena fe, atento al hecho que implica la pretensión del usuario de que el proveedor asuma las riesgos y responsabilidades que se encuentran a su cargo.

Por último, la pretensión tornaría en antieconómica la contratación informática, al tener que asumir el proveedor un cúmulo indeterminado de responsabilidades.

¹³ Al respecto ver el punto 4 del presente trabajo

Por ende, esta parte entiende que el deber de consejo tiene sus límites materiales ceñidos a lo estrictamente técnico, sin que pueda reclamársele por errores que excedan dicho marco.

Así lo entendido la jurisprudencia francesa en autos “*Cajus Face vs IBM*” fallado por la Cámara de Apelaciones de París en fecha 10 de abril de 1974. En dicho fallo se exime a la demandada IBM de la responsabilidad derivada del error en el calculo de la rentabilidad del sistema, por entender que dichos datos exceden la esfera técnica entrando en la orbita de lo empresarial.

Garantías específicas de los contratos informáticos

Durante el cumplimiento de la prestación, en los contratos informáticos existen ciertas garantías propias de la categoría que la doctrina ha denominado “*compatibilidad*”, “*modularidad*” y “*escalabilidad*”.

La compatibilidad significa que el proveedor debe garantizar la adaptabilidad de los sistemas contratados al resto de los sistemas instalados por el usuario. Algunos autores sostienen que la compatibilidad debe darse entre los componentes mismos del sistema pero, a opinión del autor de la presente, resulta un requisito redundante: Un sistema por definición constituye un conjunto organizado de bienes informáticos que cumplen una función, por ende, si no pudieran funcionar entre sí, no estaríamos frente a un sistema.

Por escalabilidad se entiende la posibilidad de migrar el sistema entregado a arquitecturas superiores o distintas, lo que hoy adquiere una particular importancia atento la velocidad del cambio tecnológico, que incrementa rápidamente las exigencias de los equipamientos y los vuelve obsoletos.

Por último, la modularidad es la posibilidad del sistema entregado de funcionar en módulos independientes, que mantienen autonomía entre sí.

Con relación al soporte lógico, el proveedor informático debe asumir la defensa de las turbaciones de derecho que puedan producirse por la propiedad intelectual del software. Ello obedece a que el usuario no tiene porque indagar acerca de los derechos que se transmiten con el contrato y el caso que se originen reclamos derivados de los derechos de propiedad intelectual o industrial, el proveedor tiene la obligación de asumir su defensa.

El moderno concepto de entrega: el test de aceptación

Es importante tener presente que, atento el carácter específico de los contratos informáticos, cuando nos referimos a la entrega debemos distinguir la mera entrega física del sistema, del cumplimiento integral de la prestación, que requiere de la instalación y puesta en funcionamiento, el test de aceptación y su aprobación.

Entre los elementos a entregar por el proveedor deben incluirse los manuales y la documentación anexa que permita un funcionamiento satisfactorio de los equipos, para lo que es menester que se establezca en el contrato las especificaciones de los mismos. Esta documentación se considera parte del soporte físico y lógico y debe incluirse en el precio del contrato¹⁴.

Respecto de la obligación de puesta en marcha en sí, si nada dice el contrato, la misma constituye una carga del proveedor informático, salvo en los casos que el

¹⁴ Bergel, Salvador, “*Contratos Informáticos en el derecho privado*”, en Carrascosa Lopez (Dir), “*Informática y Derecho*”, UNED, Vol 8, Merida, España, 1995.

usuario cuente con un sector informático o haya contratado a un tercero para llevar a cabo la tarea.

En función de ello, los proveedores cumplirán con las prestaciones de conformidad con las normas técnicas aplicadas a los buenos usos de la práctica informática. El equipo físico y el lógico estarán libres de todo defecto debido a la concepción deficiente, la falta de competencia profesional o empleo de materiales defectuosos y cumplirá con las funciones establecidas en el contrato. El concepto de buenos usos en la práctica informática implica que las prestaciones deben ser cumplidas por el proveedor de conformidad con las normas, la tecnología, la concepción (arquitectura del sistema), la fabricación, el equipo lógico, etc, propios del estado de la técnica.

La forma de determinar la correcta puesta en funcionamiento del sistema es la realización del llamado test de aceptación. Se trata de una operación de verificación que se desarrolla para comprobar que el equipo supera ciertas exigencias preestablecidas que están relacionadas con el objeto de la prestación. En tal sentido, es conveniente que el usuario establezca la previsión contractual de no aceptar el equipo hasta que el proveedor haya probado que se han superado determinadas pruebas preestablecidas.

Esto significa que la obligación de pago del precio, en los contratos de adquisición de bienes informáticos, queda supeditada al cumplimiento de las especificaciones del test de aceptación. En función de ello, el mismo deberá elaborarse cuidadosamente estableciendo los parámetros de funcionamiento aceptable del sistema, los métodos de comunicación de los incumplimientos y las formas de solución de los problemas suscitados.

Un tema a tener en cuenta en la negociación del contrato son los plazos de comunicación de las objeciones. En particular desde el punto de vista del usuario el plazo debe permitir el análisis del sistema, así como la realización de los test que delimiten los límites de funcionamiento del sistema (cuantos archivos soporta, cuantos usuarios pueden conectarse al mismo tiempo, etc.). Desde el punto de vista del proveedor, el término debe permitir establecer el final del período de prueba, con prescindencia de la efectiva comunicación del usuario. En tal sentido, es usual la inclusión de una cláusula que especifique una aceptación ficta del sistema en el caso de inexistencia de objeciones vencido el plazo establecido, así como la obligación del usuario de comunicar las objeciones dentro plazo excepto en los casos que las mismas sean derivadas de las modificaciones introducidas durante el test de aceptación.

Derechos Intelectuales: Protección del software.

Derechos Intelectuales.

1.-Concepto. Su naturaleza jurídica.

Se conocen como derechos intelectuales a todas las relaciones que se establecen entre los frutos de un trabajo intelectual, ya sean patentes de invención, creaciones artísticas o denominaciones comerciales, y su autor. Si bien normalmente se utiliza el término “propiedad” para denominar a este conjunto de derechos, ello no quiere decir que los mismos deban englobarse en los llamados derechos reales.

Al analizar los derechos subjetivos, habíamos dividido a los mismos en dos grandes grupos: personales y reales. Freitas, en su libro *“La consolidación de las leyes civiles”*, es el autor de dicha división, la cual, sostiene, da orden y engloba la universalidad de derechos posibles.

Velez Sarsfield fue influido de manera directa por el pensamiento de este autor brasileño, circunstancia que es reconocida por el propio autor del código en la nota de elevación del proyecto al congreso nacional para su tratamiento. Esta influencia no se limita a simplemente a la copia de los artículos, sino que incluso la estructura del código civil mismo refleja esta concepción: el cuerpo legal está dividido en cuatro libros: los dos primeros tratan sobre los derechos personales (relaciones de familia y relaciones civiles), en el tercero, los derechos reales y en el cuarto, las disposiciones comunes a ambas clases de derechos.

Tradicionalmente el derecho real se lo ha definido como una relación jurídica que se establece directamente entre el titular del

derecho y la cosa que su objeto. Así, por ejemplo, el dominio sobre un automotor, es una relación establecida entre el titular del mismo y el vehículo en cuestión, con prescindencia de todo otro tercero. Atento esta ausencia de sujetos pasivos determinados, el derecho real es un derecho absoluto, en el sentido de ser oponible a cualquier persona, haya tenido participación en el negocio jurídico que constituyó el derecho real o no

En sentido contrario, los derechos personales vinculan a dos o más personas determinadas o determinables, de forma tal que una de ellas (el acreedor) tiene la potestad de exigir a la otra (el deudor), el cumplimiento de una prestación determinada. Por tanto, la relación personal se establece entre estas dos partes, siendo los terceros ajenos a la misma, sin que por tanto pueda obligarlos a soportar sus efectos. Por ello es que se dice que los derechos personales generan una efectos relativos, limitándose a las partes y siendo inoponibles a los terceros.

Los derechos intelectuales, en realidad, no participan de esta gran división establecida por Freitas y Velez. En primer lugar, a diferencia de los derechos reales, el derechos intelectual no recae sobre un objeto material. Que un novelista mantenga sus derechos de autor sobre una obra, no significa que el mismo establezca una relación de dominio respecto a todos los libros impresos: Estos son propiedad de las personas que los adquirieron, limitándose el autor a recibir un beneficio económico por la explotación del texto. Sin embargo y esto es una diferencia fundamental con un derecho personal, este derecho a percibir las regalías debe ser respetado por cualquier tercero, siendo por tanto absoluto.

En el mismo sentido, debe tenerse en cuenta que el derecho de autor mantiene un segundo aspecto de carácter extrapatrimonial, que lo aleja todavía más de los derechos subjetivos tradicionales. Toda

actividad intelectual, en particular las relacionadas con el arte, tienen por fin, a falta de una expresión mejor, la gloria de su autor. Esta idea es recogida por la legislación de derechos de autor mediante los denominados derechos morales. Estos consisten, básicamente, en la obligación de reconocimiento de la autoría de la obra, así como la posibilidad de determinar el destino final de la misma.

A diferencia de los beneficios pecuniarios derivados del trabajo intelectual, los derechos morales no son transmisibles y permanecen con el autor. Así, y siguiendo con el ejemplo anterior, si el novelista hubiera vendido los derechos de explotación de la obra, no percibiría regalías, las cuales irían a manos del nuevo titular. Sin embargo, ello no es obstáculo para que tenga derecho a ser reconocido como autor de la obra y, en caso de creerlo conveniente, modificar total o parcialmente el texto o incluso solicitar el retiro y destrucción de los ejemplares, esto último, por supuesto previa indemnización de los perjuicios producidos a los terceros.

Como conclusión, podemos expresar los siguientes enunciados:

1.- Los derechos intelectuales son una clase aparte de los derechos reales y personales.

2.- El derecho de autor tiene un doble aspecto: Uno patrimonial, referido a los derechos de explotación de la creación intelectual, y otro de naturaleza extrapatrimonial, referido a los derechos morales derivados de la obra.

3.- Mientras que los derechos patrimoniales son susceptibles de transmisión, los derechos morales permanecen con el autor de la obra.

1.2.- Regulación de los derechos intelectuales en nuestro ordenamiento:

El sistema jurídico argentino regula los derechos intelectuales mediante tres leyes fundamentales, las cuales son:

- 1.- Ley 11.723. de propiedad intelectual.**
- 2.- Ley 24.481 de patentes de invención**
- 3.- Ley 22.362 de marcas y designaciones.**

A los efectos de la protección de los derechos de autor del software, la ley 24.481 carece de aplicación, por lo que no será analizada.

Si bien a primera vista pareciera una contradicción la regulación de una actividad como la informática mediante la utilización de institutos pensados para protección del autor de una obra artística, ello obedece a la necesidad de concordar la legislación argentina con la del resto del mundo. En este aspecto, la adopción del régimen de derechos de autor para la protección del software, es una solución extraída del common law. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que su equivalente en el derecho anglosajón, el copyright, presenta algunas diferencias notorias con el derecho autoral, las cuales hacen que muchas veces las regulaciones aparezcan como forzadas o poco claras.

2.- Ley 11.723 de Propiedad Intelectual. Derivados de una obra científica, artística o literaria.

2.1- Ambito e aplicación: El art. 1 del al el 11.723 sostiene que *“A los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto, las compilaciones de datos y otros materiales, las obras dramáticas, composiciones musicales, drámatico-musicales, las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas, las obras de dibujos, pintura, escultura, arquitectura,*

modelos y obras de arte o ciencia aplicada al comercio o a la industria, los impresos, planos y mapas, los plásticos, fotografías, grabados y discos fonográficos, en fin, toda producción científica literaria, artística o didáctica, sea cual fuere el procedimiento de reproducción”

“La protección de los derechos de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí”

La enumeración contenida en la norma no es taxativa y, por otro lado, la amplitud final del artículo ha permitido incluir las innovaciones tecnológicas, lo que en líneas generales ha mantenido a la ley actualizada. Esto, tal como veremos más adelante, no ha sido el caso con el software, lo que ha motivado una reforma en el art. 1, a los efectos de incluirlo expresamente.

El derecho de autor, tal como su nombre indica, necesita que la idea, como proceso eminentemente intelectual, se exteriorice en una producción, es decir un elemento corpóreo que incorpore esos fundamentos teóricos en un bien determinado y protegible. Retomando el ejemplo anterior, la ley protege la novela como ente, pero no su idea, tema o argumento: Lo tutelable es el producto en tanto existe en la realidad y no los meros proyectos o promesas.

Asimismo es necesario que la obra tenga un grado de originalidad. En este sentido, una originalidad absoluta no es concebible ni requerida, habida cuenta que todo bien cultural es expresión de la sociedad que le da cabida. Este es el fundamento principal de la limitación a los derechos de explotación que veremos más adelante.

2.2.- Tutela de los derechos. Inscripción registral:

Tal como sostuvimos en los paragrafos referidos el autor de la obra tiene derecho a la explotación de la misma, como así disponer la enajenación de los derechos económicos derivados, lo cuales son válidos por el términos otorgados por la ley para su protección.

En todos los casos, el autor siempre conserva los derechos morales sobre la obra, por lo que mas allá de la enajenación, mantiene la prerrogativa a que se lo reconozca como autor de la obra y tiene facultades de disposición sobre la misma.

A los efectos de que la protección se haga efectiva, es necesario la inscripción de la obra en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual. La ley regla de manera minuciosa el procedimiento mediante los art. 57 a 63.

A los efectos de iniciar el trámite se deberán depositar tres ejemplares completos de toda la obra publicada. Este regla encuentra su excepción en los casos de que se trate de una edición de lujo o de menos de diez ejemplares (como, por ejemplo, un software no enlatado). En tales casos, basta con depositar un único ejemplar.

Los arts. 58 a 60 fijan el procedimiento ordenando la publicación en el boletín oficial de los datos que identifiquen la obra (título de la misma, autor, clase de obra, etc). **Esta publicidad se realiza a los efectos de poder recibir las oposiciones de terceros que consideran tener derechos sobre la obra**, actividad que se realizará durante el mes posterior a la publicación.

En caso que hubiera oposiciones, se las comunicará al autor por el término de cinco días para que conteste. Vencido dicho plazo es el director del registro quien decidirá sobre la inscripción de la obra, resolución que es apelable por el término de diez días.

El art. 63, por último, define los efectos que tendrá la inscripción las cuales serán declarativos. En función de ello, y en los casos que no

exista inscripción, los derechos de los autores se suspenden, recuperándose al momento de la inscripción.

2.3 .- Titulares del derecho. Plazos. Autores extranjeros:

Según la enumeración del art. 4 de la ley, los titulares del derecho son el titular del derechos son

1.- El autor de la obra

2.- Sus herederos

3.- Los que con permiso del autor, la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la sobre una nueva obra intelectual resultante. Esto no quiere decir que, por ejemplo, los traductores o adaptadores obtengan de derechos respecto a la obra original, sino solamente a la traducción o adaptación realizada, la cual se considera una nueva obra protegible.

El derecho de autor es vitalicio y en los casos de obras en colaboración, se extiende hasta la muerte del último coautor. **Según el art. 5 de la ley extiende el derecho de los sucesores del autor por el término de setenta años** desde el 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor. En caso que el autor no tuviere herederos, los derechos derivados de la obra pasan al estado, quien puede explotarlos como si fuera un particular.

Una vez vencido dicho plazo, la obra entra en lo que se conoce como dominio público, quedando sin efecto los derechos patrimoniales derivados de la misma y permitiéndose su utilización a título gratuito por el resto de la población.

Con respecto a los autores extranjeros, los mismos se encuentran protegidos por la 11.723, siempre que acrediten el cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley. **El convención de ginebra, ratificada en el país, dispone que la exigencia de la registración, requisito fundamental para la**

protección de la ley se encontrará cumplida con la incorporación del símbolo (c) junto con el nombre y el año de la primera publicación.

Con respecto al lapso de protección para los autores extranjeros, la regla es que la protección otorgada en el país no se extenderá mas allá de la otorgada en el país de origen ni tampoco superará los establecidos en la 11.723. De esta manera, los derechos patrimoniales sobre las obras extranjeras se extenderán hasta el término menor establecido entre la legislación de origen o la argentina.

2.4.- Protección civil y penal contra la violación de la propiedad intelectual.

La tutela del derecho de autor se completa en la ley con la configuración de tipos penales específicos, la posibilidad de la denuncia publica ante el registro y la substanciación de un procedimiento civil particular.

En el aspecto penal, el art. 71 impone al que defraude los derechos de propiedad intelectual de otro, la pena establecida en el art. 172 del Código penal, el cual impone un mínimo de seis meses y un máximo de seis años de prisión al autor penalmente responsable.

Asimismo el art. 72 fija algunos tipos particulares como casos específicos de defraudación, a los cuales se debe aplicar la pena del 172 del Cod. penal.

Las acciones penadas son la siguientes:

- 1.- El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor
- 2.- El que falsifique la edición de una obra ya editada, ostentando falsamente el título del editor autorizado.

3.- El que reproduzca o venda una obra, modificando el nombre del autor, el título o el texto dolosamente.

4.- El que edite o reproduzca mayor número de ejemplares que los convenidos con el autor.

Todos estos delitos pueden ser denunciados por cualquier particular o incluso pueden ser iniciados de oficio por la autoridad pública, circunstancia que, en la provincia, es obligatoria en los casos en que un agente de la administración pública tenga noticia de la comisión de los delitos. Asimismo, y atento la pena máxima impuesta, **no gozan del beneficio de la excarcelación.**

El procedimiento civil presenta algunas particularidades: en primer lugar constituye un procedimiento abreviado. La ley hace referencia a la aplicación de las reglas de excepciones dilatorias. Atento la modificación del código de procedimiento serán de aplicación las reglas de las excepciones previas, que son la figura procesal que suplantó a las anteriores.

La novedad principal respecto es la posibilidad de formación de un jurado técnico, el cual podrá ser presidido por el decano de la facultad de Filosofía y Letras, Exactas, del Museo Nacional de Bellas Artes o el Conservatorio Musical. **Este jurado de notables cumple las funciones de la prueba pericial, debiendo declarar si existe o no lesión a la propiedad intelectual.** Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el dictamen no es vinculante.

De la misma forma, esta vez restringido a las obras que se encuentran en el dominio público, cualquier particular puede denunciar ante el registro nacional de propiedad intelectual la modificación o cercenamiento de la obra. En tales casos el registro debe constituir un jurado expertos a los efectos de dictaminar sobre la veracidad de la denuncia. A diferencia del proceso civil, en este caso el

dictamen es vinculante y puede imponer multas y/o secuestrar la obra objeto de reclamo.

3.- Marcas y Denominaciones comerciales

3.1.- Concepto:

Un mercado solo puede operar eficientemente cuando los consumidores realizan sus decisiones luego de haber recibido la información apropiada. Para ello es necesario que el público pueda diferenciar entre un producto y otro. En todo mercado en el que existe más de un productor de un bien o servicio, es necesario que exista signos exteriores en los mismos, de forma tal que los consumidores puedan diferenciar los mismos claramente. Es a partir de la existencia e interacción de estos signos, que se busca evitar toda confusión entre los posibles productos.

Por tanto podemos decir que **la marca es el signo característico y distintivo con que el productor de un bien o prestador de un servicio distingue sus productos o servicios**

Hoy en día, y en función de la extensión de la economía de masas, las marcas comerciales superan su función primaria de identificar un producto para constituir un bien económicamente valioso. La publicidad y el marketing generan una asociación entre una determinada marca y un grupo de valores o aspiraciones sociales que permiten una mejor comercialización, al establecen una identificación entre el usuario, el producto y los valores presentados. Así, por ejemplo, la automotriz Volvo invierte grandes sumas de dinero los efectos de ser asociada con los valores de confiabilidad y seguridad. Esto permite una mejor comercialización del producto, lo que redundará en mayores márgenes de ganancia.

Si bien la ley de propiedad intelectual es consagra la protección de software como obra, nada ordena respecto a los signos distintivos que el mismo, como producto comercial, emplee para distinguirse de

sus semejantes. Por ello, y a los efectos de su protección, es necesario el estudio de la legislación de marcas.

3.2.- Clasificaciones:

La clasificación de las marcas puede hacerse mediante los más diversos criterios. Entre los principales podemos mencionar:

1.- Marcas de productos y marcas de servicios: Las marcas tradicionalmente han distinguido productos. Recién con en el año 1967 con la firma del convenio de París, se introdujeron las marcas de servicios. Hoy día la ley 22.362 adopta la clasificación internacional determinando que las clases 1 a 34 corresponden a productos y la 35 a 42 a servicios.

2.- Marcas registradas o de hecho: Dependerá si las mismas se encuentran inscriptas o no. En principio, y salvo excepciones, solamente las registradas tienen protección legal.

3.- Marcas originales y de defensa: Las marcas de defensa son aquellas inscriptas en categorías diferentes a la del producto y servicio que representa. Su función es evitar que la marca original se diluya, mediante la proliferación de productos de igual nombre en otras rubros. Veremos el tema con más detalle al analizar la cuestión de las categorías.

3.3.- Régimen Aplicable:

3.3.1. El concepto de marca: El art. 1 plantea un criterio amplio en lo referente a que es lo que puede considerarse marca. Entre otras cosas, enumera que pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios una o mas palabras, los dibujos , emblemas, monogramas, combinaciones de alfanuméricas, de colores, formas

geométricas o cualquier otro signo con capacidad distintiva. La enunciación no es taxativa, atento lo observado por la última parte del art.

Los art. 2 y 3, en sentido contrario, limitan cuáles son las marcas posibles de registrar. Así, el art. 2 no permite considerar marca a la características habituales del producto como su nombre genérico, las cualidades del mismo, la forma, su color o cualquier característica que haya pasado al uso general antes de la inscripción.

En el mismo sentido, el art. 3 no podrán ser marcas las denominaciones de origen, las expresiones que puedan dar lugar a error respecto a las características del objeto o aquellas reservadas a la nación, provincias estados extranjeros, o cualquier otra persona de derecho público.

3.3.2. Adquisición del derecho. Régimen de inscripción:

El art. 4 de la ley establece la necesidad de inscripción registral de las marcas y otorga a las mismas carácter constitutivo, al ordenar que la propiedad de una marca y su exclusividad se otorgan con la inscripción. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este principio no es absoluto, ya que muchas veces la jurisprudencia ha protegido marcas no inscriptas, aún las extranjeras, en los casos que las mismas sean notorias.

Otra característica particular de la regulación marcaría es que la inscripción se realiza en distintas categorías preestablecidas, de forma tal que una misma marca (normalmente en los casos en que se trate de palabras o expresiones alfanuméricas) puede aludir a productos o servicios diferentes. Tal sería el caso, por ejemplo, de una panificadora llamada Sublime y una marca de cal del mismo nombre. En ambos casos, la inscripción podría realizarse, ya que las marcas refieren a productos sin ningún tipo de relación.

El art. 10 y siguientes legisla lo relativo al trámite de registro de las marcas, estableciendo que se deberá presentar una solicitud por cada clase que se solicite y constituir un domicilio en la Capital Federal, en el cual se realizarán todas las notificaciones del procedimiento de inscripción.

Presentada la solicitud y realizado un primer examen de legalidad por la autoridad de aplicación, se realiza una publicación por un día en un boletín especial denominado "Boletín de Marcas". Una vez finalizada la misma, la dirección nacional de propiedad industrial en su carácter de autoridad de aplicación de la ley tiene treinta días para realizar un estudio de los antecedentes del pedido. En el mismo lapso, los particulares con un interés legítimo, podrán oponerse al otorgamiento de la marca, mediante una presentación por escrito, el cual de estar fundamentada.

Habiendo mediado oposición o no, y en el primer caso, cualquiera fuera el resultado, la dirección podrá negar la inscripción si considera que no se reúnen los requisitos de la ley. En tales casos, tal resolución puede ser impugnada por demanda ordinaria contra la autoridad de aplicación, la cual deberá ser interpuesta dentro de los treinta días de notificado el acto administrativo, entendiendo en la causa la justicia federal civil y comercial.

3.3.3. Lapso de duración de la marca. Las marcas de defensa.

El término de duración de una marca comercial es de 10 años, prorrogable indefinidamente por el mismo lapso a instancias del titular de la misma.

El único requisito que la ley obliga a cumplir para la renovación es la utilización de la marca por lo menos en una de las categorías inscriptas en el término anterior. De manera que es posible inscribir la

marca en categorías que en realidad jamás se tuvo la intención de usar. Estas se conocen como marcas de defensa.

La razón fundamental para tomarse esta molestia es evitar el fenómeno que se conoce como disolución de marca. Tal como se dijo en la introducción de este capítulo, las marcas comerciales constituyen un valor en si mismo toda vez que se relacionan con ciertos valores impulsados desde el marketing. Pero esta relación debe ser mantenida, evitando que la misma se pierda mediante la introducción de productos que no cumplan las expectativas que los consumidores tienen la marca. El fenómeno de la disolución, entonces, permite que terceros, ajenos a la productor original, se sirvan del valor de la designación comercial, utilizándola en objetos o servicios que no tienen directa relación con el original. De esta forma no solo consiguen un beneficio sin causa sino que diluyen la marca original, la cual ahora se expande en categorías no previstas ni queridas por fabricante original. Para evitar ello, se utilizan las llamadas marcas de defensa, las cuales impiden el registro por parte de terceros y limitan la dilución en los rubros que normalmente podrían beneficiarse de la confusión.

3.3.4.- Protección civil y penal:

Al igual que la ley de propiedad intelectual, el derecho de marcas organiza tipos penales y reglamenta una acción civil a los efectos de su defensa.

En este sentido el art. 31 define una serie de tipos penales específicos, los cuales mantienen una pena de tres meses a dos años de prisión. Las conductas punibles abarcan a quien falsifique una marca registrada, quien la utilice sin autorización o quien la comercialice. Estos delitos son de acción pública y tramitan ante la justicia federal.

La acción civil seguirá el trámite del juicio ordinario ante la justicia federal en lo civil y comercial y perseguirá la cesación en el uso no autorizado de la marca

Tanto el querellante en la causa penal como el demandante en la civil pueden solicitar se ordene el secuestro de las mercadería que lleven la marca en infracción. Asimismo el régimen de medidas precautorias es notoriamente más accesible que el regulado por la ley de propiedad intelectual. Esta característica lo hace particularmente útil en la defensa jurídica del software, utilizando la defensa de la marca comercial para solicitar el secuestro de las copias ilegales.

4.- Defensa Jurídica del Software

Tal como vimos al analizar el art. 1 de la ley 11.723, en la actualidad los obras del software se encuentran protegidas por la ley. Sin embargo, esta modificación es relativamente moderna y es el resultado de una discusión referente a la necesidad o no de legislar el tema y aun en caso afirmativo, cuál era la mejor forma de hacerlo.

La doctrina se dividía básicamente entre quienes sostenía que la enunciación del art. 1 era lo suficientemente amplia como para incorporar a los programas de computación y aquellos que por el contrario entendían que era necesaria una recepción legislativa expresa, ya sea mediante la reforma de la ley de propiedad intelectual, sea mediante la sanción de una ley específica al efecto.

Hasta el año 1997, la primera de las visiones prevaleció. El decreto del poder ejecutivo nacional 165/94 otorgaba el carácter de obra tanto al software como a los bancos de datos, en la concepción que dicha reglamentación permitía incluir a dichas creaciones dentro de la protección tanto penal como civil otorgada por la ley 11723.

Esta concepción entró en crisis en el año 1997 mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Pellicori, Oscar y otros s/Denuncia por defraudación” o como popularmente se lo conoció, el caso Autodesk. En dicha sentencia, la corte entendió que la venta de programas sin licencia, lo que vulgarmente se conoce como piratería, no constituía un delito dentro del ordenamiento argentino. El fundamento del fallo establecía que la reglamentación de una ley, cosa que era el decreto 165/94, no podía ampliar los bienes protegidos por una ley, toda vez que ello implicaba una modificación a la misma. Por tanto, y por lo menos desde el punto de vista penal, la conducta no era punible, ya que no había una ley que estableciera la misma como una actividad ilícita.

Este fallo, que generó una amplia cobertura en los medios masivos de comunicación, determinó la sanción de la modificación de la ley 11723 a los efectos de incorporar en su art. 1 al software y los bancos de datos.

La incorporación del software y las bases a la ley de propiedad intelectual, tiene asidero en los antecedentes en el derecho internacional y en la doctrina y legislación comparada. En este sentido, la república argentina ya había firmado el acuerdo TRIPS, ratificado por ley 24245 disponiendo que *“los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias según el convenio de Berna.”*. En este sentido, la incorporación del software a la ley de derechos de autor, guarda directa relación con la legislación del *Common Law* inglesa y americana. En estos ordenamientos el *copyright*, funciona como un equivalente a la expresión derechos de autor, aunque dicha similitud no es total.

En función de ello, la solución adoptada, fue criticada por aquellos autores que entendían hubiera sido conveniente la sanción de una ley específica. El problema fundamental en referencia a la inclusión lisa y llana a la legislación de los derechos de autor, es que el instituto fue concebido tradicionalmente en el derecho continental como una mecanismo de defensa de los derechos de las creaciones científicas y particularmente artísticas: Así, la existencia de derechos e incluso el lapso de protección de los derechos durante setenta años aparece como exagerado o por lo menos de dudosa aplicación directa a una obra como el software, que tiene más puntos de contacto con un producto comercial que con una expresión de la individualidad de su autor.

En otro sentido, la protección procesal obtenida mediante la ley de derechos de autor aparece muchas veces como deficiente, siendo conveniente el registro de la marca a los efectos de lograr el secuestro

de las copias ilegales o incluso las máquinas donde estas se encuentran contenidas.

4.2.- Breves nociones en referencia a las licencias de uso, cesión de código fuente y software libre.

Por último analizaremos algunos de los mecanismos contractuales más comunes referidos a la cesión dl derecho de uso de un programa y las diferencias fundamentales referidas al software libre y propietario.

Un contrato de licencia de uso es aquel por el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual sobre un programa, transfiere a la otra parte, conocida como licenciataria, el uso y goce del programa. Pero el titular de la licencia conserva la titularidad del programa y limita en forma clara cuáles son las actividades que el licenciataria pueda realizar. En este sentido, esta prohibida la reproducción total o parcial del programa, salvo la excepción derivada del derecho de realizar una copia de seguridad del mismo.

Es usual, asimismo, que solo el código objeto o programa compilado sea entregado al licenciataria, al cual se le prohíbe realizar retroingeniería a los efectos de lograr un nuevo código fuente. Como contrapartida, el licenciante normalmente asume la obligación de realizar el mantenimiento o actualización de los programas licenciados, durante la duración de la relación contractual.

Sin embargo, puede haber casos en que sea necesario el acceso al código fuente. Tal es el caso que la empresa licenciataria tenga interés en realizar un desarrollo propio a partir del programa adquirido o en cuando, en función de consideraciones económicas decida prefera hacerse cargo del mantenimiento y/o actualización del

software. En estos casos, es normal realizar una cesión del código fuente.

Un contrato de cesión de código fuente entrega no solo el uso y goce de la software desarrollado sino, y tal como su nombre lo indica, el código originalmente escrito por el programador en lenguaje de alto nivel, de forma tal que otorga al cesionario del mismo la capacidad de realizar modificaciones y compilarlas, generando un nuevo código objeto. Puede decirse que en tales casos el autor del software pierde el control sobre el destino del mismo, circunstancia que suele verse reforzada por cláusulas de exclusividad de explotación en beneficio del cesionario.

En la práctica, la elección de una u otra forma contractual depende fundamentalmente de la capacidad negocial de las partes. Usualmente, el desarrollador del software tiende a la utilización de la licencia de uso, de forma tal de asegurarse los beneficios derivados del contrato de mantenimiento, así como mantener la exclusividad de la explotación del programa. Excepcionalmente podría optar por la entrega del código fuente en los casos de software a medida y cuyas soluciones no podrían aplicarse a nuevos emprendimientos. Sus co-contratantes, en cambio, y sobre todo en el caso que cuenten con un departamento informático, optan por la entrega del código fuente, evitando el costo derivado del contrato de mantenimiento y los riesgos de una posible desaparición del proveedor informático y con el la posibilidad de actualización del software.

Software libre: Popularmente se ha entendido que el software libre se caracteriza por una absoluta libertad respecto a su utilización, configurándose como una respuesta a la idea de propiedad y explotación comercial de los modelos tradicionales de comercialización conocidos como software propietario.

En realidad, el software libre no carece de limitaciones. Cada persona que utiliza un software sometido a este régimen acepta una licencia general de uso que impone derechos y obligaciones. A diferencia de una obra de dominio público, la cual puede ser utilizada con fines comerciales, el software libre impide al usuario la comercialización de los desarrollos realizados bajo el sistema. La licencia general de uso prohíbe la posibilidad de cobrar por el programa entregado, más allá de los costos de distribución física del mismo (soporte óptico o magnético, el precio del envío, cajas, ect.)

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre el software libre y el gratuito (freeware). **La característica fundamental del software libre es la obligación de todos los desarrolladores de poner disponible el código fuente a cualquier usuario que así lo solicite,** de forma tal que estos últimos puedan realizar las modificaciones que estime conveniente y distribuirlas nuevamente.

De esta manera, el software libre se convierte en una creación colectiva, en la que, por lo menos en teoría, todos usuarios se encuentran en pie de igualdad al poder modificar el programa y adaptarlo a sus necesidades específicas.